





**جامعة المستقبل**

**كلية الشريعة**

**قسم أصول الفقه**

---

**بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس**

# بعنوان : الحالات التي يفرق القاضي بين الزوجين.

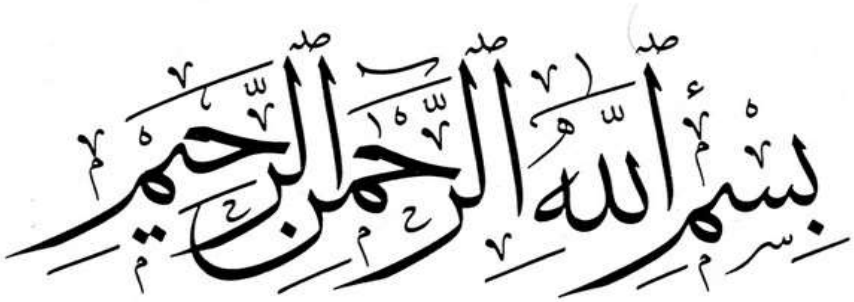
**إعداد الطالبة: حبيبة ابشر حرص**

**الرقم الجامعي: ٣٨٥٥١.**

**الإشراف: الدكتور: يوسف عريس**

**العام الدراسي :هـ١٤٤٢-الموافق ٢٠٢١م**

# استهلال




وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

سورة النور 32

# إهـــــــــداء

إلى أمي.... من علَّمتني العطاء، وغمرتني بحنانها وكرمها.

إلى أبي..... من رحل عن عالمنا، وما زال دويٌّ نصائحه يوجهني.

إلى إخواني الخلوقين.... من علَّموني أن الحياة من دون ترابط وحب وتعاون لا تساوي شيئًا.

إلي أخواتي أنسي وشرفي وسر سعادتي.

إلى ابني.... وقلبي النابض

إن إنهائي عملي لم يكن ليتم لولا دعمكم، وأتمنَّى أن ينال رضاكم.

# شكر وتقدير

أبدأ بشكر من شكره الشاكرون المتفضل علينا بنعم لا تحصى كثرتها، ولا يحيط بعظمتها إلا هو سبحانه، فله الحمد والشكر أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً؛ لأن الشكر سبب المزيد من فضله. قال تعالى: (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ).

إلى من بلغ الرسالة، وأدى الأمانة ونصح الأمة نبي الرحمة، ونور العالمين .

إلى من تعلمت فيها معنى الأخلاق والعلم، إلى جامعة المستقبل الصرح العلمي الشامخ .

وأخص بجزيل الشكر والعرفان كل من وقف على المنابر، وأعطى حصيلة علمه لينير دربنا .

ثم أتقدم بالشكر الى أساتذتي بجامعة المستقيل الذين لم يبخلوا عليّ بوقتهم، وإلى جميع العاملين بها سائلة الله سبحانه وتعالى أن يجعلها قبلة للعلم.

وأخص بالشكر أستادي د: يوسف عريس الذي أشرف على هذا البحث وتفضل عليَّ بالتوجيه.

**المقدمة.**

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين،سيدنا محمد، وعلى آله وصحبة الطيبين الظاهرين، وعلى التّابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

سبحان الله الحكيم في تقديره النكاح، وهو الحكيم في شرعه الفراق،والله يغني الناس بالجمع قال تعالى: إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )[1](، والله يغني الناس من الفراق قال تعالى( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا)[2]

فكما عبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم–قد اعتبر التفقه في الدين علامة خير وإشارة محبة من الله حيث قال: رسول الله صبى الله عليه وسلم(من يرد الله به خيرا يفقه في الدين)[3] وإذا كان الفقه بمختلف موضوعاته وبشتى أبوابه خطي تلك المنزلة العطية،والمكانة الرفيعة العالية فلا شك بأن الفقه الإسلامي كنز هذه الأمة وثرواتها الذاتية.

ولا يخفى ذلك على من له ذوق بأدبي معرفة الشريعة الإسلامية واطلاع كلياتها و تضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئتها بغاية العدل الذي جعل بين العباد وأنه لاعدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح بين الناس .

وإن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها وكلية من كلياتها.

ومن هذه السياسة أن جعل للقاضي سلطة الفصل بين المتخاصمين نبراسة فيها كتاب الله و هدى نبيه واستنباطات علمائه الأطهار، الذين سهرت أعينهم لحراسة دينه وإحقاق الحق والعدالة بين الناس مهما كانت درجته وعلمه وسلطته وجاهه .

---

[1] سورة النور الآية 32

[2] سورة النساء 130

[3] أخرجه الترمذي

فالفقه أثمر توسعة على الأمة في دينها في تطبيق أحكام شريعتها ومن بينها حل المشاكل الأسرية الناشئة بين الزوجين واستعجال الأمر والخروج من يدهما ليلتجأ إلى سلطة العدالة أمام مجلس القاضي .

والشريعة جاءات لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد ومضراتها وتقليلها مهما أمكن ذلك .

فالواجب القضاة أن يبذلوا قصارى جهدهم نحو كل ما يحقق المصالح و يبعد المفاسد، لا سيما فيما يتعلق بالمشاكل الأسرية التي جعل الله حكمة و أنسا وإعفافا فيما بينهما، وحصول المصالح المنشودة من غاية الأسرة المسلمة وإعطاء كل واحد من الزوجين حقه، حتى تنجوا السفينة ومن عليها من الغرق، ويتحقق الوئام والاستقامة فيما بينهما يتحقق ذلك، فإن تعذر الصلح بجميع طرقه وو سائله فرق بينهما، لتعذر البقاء الزوجة.

والتفريق بات ضروريا في الأوينة الأخيرة لأنها كثرت المشاكل التي تحصل بين الزوجين من حين لآخر وبهذا تتطلب التدخل القاضي ليختار أخف الضررين وهو التفريق بين الزوجين لكي ينعم كل منهما حياة سعيدة بدون مشاكل.

ومن ثم فقد اختارت الباحثة موضوعا لحالات التي يفرق القاضي بين الزوجين مجالا للبحث

**. أسباب اختيار الموضوع**

1- الرغبة الشديدة في كتابة رسالة علمية في هذا العنون.

2- شعور أنها حاجة ماسة للأمة في إنارة هذا الموضوع.

3- كثرة الاختلافات الأسرية التي ظهرت في الأوينة الاخيرة.

4- فيه عدم معرفة المتفرقين العواقب التي تترتب بعد التفرق.

**مشكلة البحث**

1- تهدف الدراسة إلى إيجاد فقه لموضوع مهم من مسائل الاحوال الشخصية.

2- يعالج مشكلة عدم فهم المتفرقين كيقية حدوث التفريق بينهم.

3- يحل تكرار خلل في كيان الاسرة المسلمة.

4- يحل يعالج بعض الأوقات يحصل إضطهاد للمرأة يجبرها للجوء إلى القاضي وطلب منه التفريق ؟

5- عدم التعمق في مسائل التفريق القاضي بين الزوجين حيث تتعدد الأسباب والمبررات للتفريق وحل عقدة النكاح.

**- أهمية البحث:**

1- يسعى إلى تحقيق ما يحققه مصالح الأمة ويراعي المقاصد العامة، مما يجعل هذه المصالح أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد في العاجل والآجل، وإزالة الظلم و الضرر والتعالي عن حقوق الآخرين .

2- يعدّ البحث الحالي محاولة للتعرف على الاسباب الزوجية المرتبطة بالمرحلة الأولى من الزواج والتي تسهم في حدوث التفريق عموماً والطلاق المبكر على وجه الخصوص.

3- أنه يعالج ناحية من نواحي الحياة الأسرية (نظام الأسرة).

4- يعدّ البحث الحالي إضافة نظرية للأبحاث المهتمة بالمشكلات الزوجية التي تؤدي بالزوجين إلى التفريق وإنهاء الحياة الزوجية لاسيما في الوقت الحالي على أساس أنَّ مشكلة التفريق قد درست سابقاً وقدمت لها الحلول المناسبة، ومن يحاول دراستها حالياً سوف لا يأتي بجديد

**أهداف البحث:**

يهدف البحث إلى:

1- التعرف على اسباب التفريق عامة والأسباب التي تقف خلفها.

2- التعرف على موقف الشريعة الإسلامية من التفريق القضائي.

3-التعرف على جهة إصدار الحكم.

4- وضع التوصيات التي من شأنها أنْ تعالج هذه المشكلة أو تحد من آثارها على الفرد والمجتمع.

**منهج البحث**

سأتبع المنهج الاستقرائي وفق الخطوات التالية:

1- جمع المعلومات المتفرقة التي ذكرها الفقهاء في بطون كتبهم حول هذا الموضوع.

2- تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول تحت كل فصل مباحث إن شاء الله.

3- الاعتماد على المصادر الأصلية، ثم توثيقها في الهامش، وأذكر لما يلي: اسم الكتاب اسم المؤلف الكتاب-دار النشر-الطبعة-تاريخ النشر-الصفحة.

4- سأشير إلى مواضع الآيات القرآنية بأرقامها في السور التي وردت فيها بالهامش.

5- عرض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في الخاتمة البحث.

6- إعداد الفهارس العلمية الخاصة بالبحث.

**اسئلة البحث**

1- ما التكيف الفقهي للتفريث القاضي؟

2- هل ينحصر الفرقة بين الزوج باعتباره صاحب الحق الاصيل؟

3- ما جهة الإصدار الحكم؟

4- ما موقف الشريعة الاسلامية من التفريق القضائي؟

**حدود البحث**

حدود موضوعية: حالات التي يفرق القاضي بين الزوجين.

حدود زمانية: 2020–م2021

**وسائل وأدوات البحث**

تستعين الباحثة في بحثها– إن شاء الله الوسائل والأدوات الأساسية للبحث العلمي مثل المراجع والمصادر الأصلية من الكتب والموسوعات والمكتبة الألكترونية والشبكة العنكبوت وكل وسيلة ضرورية الإنجاز هذا البحث

**هيكل البحث.**

**ويشتمل هذا البحث إلى ،مقدمة- وثلاثة فصول-وخاتمة .**

**الفصل الأول:مقدمة.**

جهة اصدار الحكم.

المبحث الاول: القاضي، تعريف القاضي.

المبحث الثاني: شروط القاضي قي الإسلام، آداب القاضي، نقص الحكم وأثره.

المبحث الثالث: مجال التحكيم في مسائل التفريق وعلاقة التحكيم بالقاضي.

الفصل الثاني: مقهوم التفريق القضائي.

المبحث الاول: تعريف التفريق لغة وفي إصطلاح الفقهاء.

المبحث الثاني: أسباب التفريق القضائي.

اسباب طلب التدخل القضائي

أسباب اللجوء الزوج إلى القاضي.

أسباب اللجوء الزوجة إلى القاضي.

المبحث الثالث: أسباب اللجوء الولي إلى تفريق القضائي.

الفصل الثالث: التكيف الفقهي القضائي للتفريق ومشروعيته.

المبحث الاول: صاحب الحق في فرقة بين الزوجين.

السلطة الممنوحة للزواج في استخدام حق الطلاق.

المبحث الثاني: مشروعية التفريق.

المبحث الثالث: موقف الشريعة الإسلامية من التقريق القضائي وآراء الفقهاء كله.

**الخاتمة:** ويتضمن

**1**–النتائج

2– التوصيات.

**الفهارس ويتضمن:**

1–فهرس الآيات.

2- فهرس الأحاديث.

3- فهرس والمصادر والمراجع.

4- فهرس الموضوعات.

## الفصل الأول

## جهة إصدار الحكم

**تمهيد :**

موضوع الدراسة ليس القضاء بصفة عامة أو التعريف بالقاضي وشروطه وكيفية تنصيبه إلا أنني وجدت من الضرورة الحديث عن الجهة المصدرة للحكم القضائي بصفتها مقوما من مقومات نظرية التفريق كما أن هناك مباحث مهمة في الحديث عن القضاء والقاضي لها صلة بموضوع التفريق، وخاصة في أوقاتنا المعاصرة، التي يعيش فيها المسلمون في شتى بقاع الدنيا في البلاد الإسلام وغير الإسلامية، وحتى البلاد الإسلامية فان منها من يحتكم إلى أحكام الشريعة ومنها من لا يتحكم، ومنها ما تختلط فيها الأحكام، ويتبع التعدد في الأنظمة القضائية، وتعيين القضاة في تلك الدول والتى لا ينفك المسلم في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية التي تعنى بالزواج والفرقة من التحاكم ومراجعة النظام القضائي القائم، أو قد يضطر إلى اللجوء إليه بحكم القانون العام في الدولة الآمر بذلك .

لكل ذلك رأيت ان أضم هذا الفصل إلى موضوع الدراسة لتجلية بعض المفاهيم والأحكام فيها، ولذا سيكون الطرح هنا متجها الى خدمة هذاالهدف دون الخوص فى كثير من التفصيلات التى محلها كتب القضاء. ومما سأحاول بيانة الجهة الرئيسة فى العملية القضائية وهو القاضي .

## المبحث الأول

## القاضي

**تعريف القاضي** : درجت أكثر كتب الفقه على البدء بتعريف القضاء ووضعت لذلك حدودا ورسما، وعند الحديث عن القاضي توجه التصنيف إلي بيان شروطه وآدابه، لذا فإننا من الممكن أن نصل إلى تعريف القاضي من تعريفهم للقضاء، والمتأخرون عرفو القاضي بأنه الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان لأجل فصل وحسم الداعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامها المشروعة.[١]

**تعريف القاضي في اللغة:** له عدة معان:

ألأول :فياتي بمعنى الخلق: ومنه قوله سبحانه وتعالى :(فقضاهن سبع السماوات فى يومين )[٢]

وبمعنى الحكم: ومنه قوله تعالى : (فاقض مآنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ) .[٣]

واصطلاحا: قال الشافعي: فصل الخصومة بين خصمين فاكثر بحكم الله تعالى .[٤]

اتفقت كلمة الفقهاء على أن القاضي لايكون كذلك حتى يولى من صاحب الولاية العامة في الدولة ، وذلك للتمييز بينه وبين المحكم ولتكون له ولاية عامة مستمدة التي قامت بتعيينه.

**القاضي لغة:** القاطِعُ للأمور المُحكِمُ لها أو من يقضِي بين الناس بحكم الشرع.

**وشرعا:** من تعيّنه الدولةُ للنظر في الخصُومات والدعاوَى وإصدار الأحكام التي يراها طبقاً للقانون، ومَقَرُّه الرسمي إحدى دور القضاء. والجمع: قُضَاةٌ. ويقال: سُمٌّ قاضٍ: أي قاتل[٥].

---

[١]–المادة ١٧٨٥ /مجلة الاحكام العدلية

[٢]– سورة فصلت الآية ١٢

[٣]– سورة طه الأية (٧٢)

[٤]– الشربيني :ا معنى لمحتاج ٣٧٢/٤

[5] - .يناير ٢٠١٥ على موقع واي باك مشين 17 نسخة محفوظة المعجم الوسيط

## المبحث الثاني

## شروط القاضي في الإسلام

هناك شروط متفق عليها ومختلف فيها نذكرها سبيل الإيجاز :

### الشروط المتفق عليها:

**أولا : الإسلام** : يشترط في القاضي أن يكون مسلما، فلا يجوز ان يتولى القضاء غير مسلم ، لأن الكافر ليس له أهليةالولاية على المسلم، لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا .[1]

وقولة تعالى: (قاتلو الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ولايحرمون ما حرم الله ورسوله ولايد ينون دين الحق)[2]

والقصد من القضاء فصل الخصومات والمنازعات وغير المسلم جاهل بأحكام الشريعة.[3]

### ثانيا البلوغ

فلايصح ولاية الصبي القضاءحتي ولو كان مميزا وعرف بالذهاء والقطنة والعبقرية وهذا امر مجمع عليه ولم أقف من خالف ذلك من اهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبان .[4]

---

[1]- سورة النساء ،الاية (١٤٥)

[2]- سورة التوبة ،الآية (٢٩)

[3]– أجاز الأحناف اذا القضاء مواطن غيرمسلم فانه قضائه ينفد واليه ذهب الاحناف واستدلوا بعدة أدلة منها :قوله تعالى :"(يا أيها الذين أمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم.....) سورة المائة،الاية (٥١) وجه الاستدلال من الاية: ان للكفار ولاية بعضهم علي بعض، وهذا يتناول دلالة القضاء بعضهم على بعض وذهب الجمهور الى عدم الجواز واستد الكبرى للامام الشعراني ،(٢٥٧/٢ )، رد المختار لابن عابدين (٨٧/٧ _٨٣ )،بدائع الصنا ئع(٢٣٨/٥ ) بداية المجتهد لوا بقوله صلى الله عليه وسلم : " الاسلام يعلوا ولايعلي عليه" أخرجه ألدار القطني ،انظر :سبل السلام(١٣٧٦/٤_١٣٧٧) ،لميزان (٥ /١٧٦٨ ) ،الحاول الكبر (١٦/ ٢٢٧) مفتي المحتاج (٦/ ٢٧٠ ) ، الغني لابن قدامة(١٤/ ١٢_ ١٧

[4]- أخرجه أحمد وانظر :أيضا تفصيل نيل الاوطار للشوكاني (١٧/٩)الروضة للفتوحى (٣٥٤/٢)

**وجه الاستدلال من الحديث:**

النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بأن تعوذ من إمارة الصبيان ولايكون التعود إلا من شر ، فتكون إمارة الصبيان شرا، ونحن نمنع من ارتكاب الشر فتكون توليهم ممنوعة .[١] واستدلو أيضا بأدلة عقليه منها : أن القضاء محتاج الى العطه وكمال الرأي وتمام العقل ، والصبي لاتتوافر فيه فلا يصح توليه [٢] .أن يكون له والولاية لغيره .

ان تولية الرئاسة منصب عام بالنظر رالمصلحة ولا تتحقق المصلحة في تولية الصبي منصب القضاء .[٣]

**ثالثا العقل :**

إذا كان لا يصح تولية الصبي القضاء فتولية المجنون من باب أولى.[٤] والعقل احد الشروط المجمع عليه بين العلماء ، ولايتصور الخلاف في ذلك، وقد عرف بعض العلماء العقل " غريزة يتأتي بها درك العلوم "[٥] وقد عرفه السبكي: بقوله: " ملكة يتاتي بها درك المعلومات"

محل العقل : اختلف العلماء في محل العقل ، فالشافعية يقولون : إن محل العقل هو القلب ، واستدلوا على ذلك نصوص قرآنية والسنة منها:

آما الكتاب: ١_ قوله تعالي :( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور)[٦]

٢_وقوله تعالى :( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لايبصرون بهاولهم آذان لايسمعون بها) [١]

---

[١]– نيل الاوطار (١٦٧/٩)

[٢]– المغني ،لإبن قدامة، (١٣/١٤_٢٥).

[٣]– فتح القدير،(٢٧٠/٩)

[٤]– هو :أحمد ابنعلى ابن عبدالكافي أبو حامد، ولد سنة (٧١٩)، فقيه شافعي له مؤلفات كثير منها:"عروس الأفراح"، الاشباه والنظائر،

[٥]– الاشباه والنظائر ،للسبكي (١٧/٢)

[٦]– سورة الحج ،الأية (٤٦).

٣_وقوله تعالى :( وإن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو الشهيد ) .[٢]

ومن السنة : قوله تعالى: "(الا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله"[٣]

الشروط المختلف فيها:

اولا : العدالة [٤]: فالفاسق ممنوع من تولى القضاء مع انه أحسن حالا من الكافر ، فلا يتولي الولاية الكافر كما تقدم ويمنع الفاسق تولى السلطة القضاء ، إذا غابت صفة العدالة في شخصية المتولي بها يولي ؛ لأن هذه الولاية العظيمة لا يولي من لا تظهر فيه صفة العدالة وإليه ذهب الأئمة الثلاثة.[٥]

وذهب الأحناف بعدم اشتراط العدالة.

**أدلة الأحناف : استدل الأحناف أدلة نقليه منها :**

١_-- قوله تعالي :(ياأيها الذين آمنوا لا تتخذو اليهود والنصاري اولياء بعضهم اولياءبعض )[٦]

وجه الإستدلال من الآية : فقد أفادت الأية الكريمة ان لكفار ولاية بعضهم عنبعض فيشتمل الولاية القضاء فيما بينهم وغيرهم .

---

[١]- سورة الحج ،الأية (٤٦).

[٢]- سورة الأعراف، الأية(١٧٩).

٣- سورة ق الأية (٣٧). هي : صفة زائدة على الإسلام ، وهو أن يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته "،بداية المجتهد ،(٤/ ١٧٧٢).

[٤]- البخارى باب المسا فا ت (٢٠/١)، البيهقي (٢٦٤/٥)

[٥]- بداية المجتهد،( ١٧٧٣/٤) ، الرضة (٢٥٤/٢_٣٠). المغني ،لابن قدامة!١٢/٤_١٨)، الكافي ،لابنقدامة، (٨٦/٦)، الميزان الكبرى ،(٢/٢٨_٢٦١).

[٦]- سورة المائدة ، الأية (٥١)

٢_قياص القضاء على الشهادة : إذ أن العرف جرى فى البلاد الإسلاميه مند فخر الإسلام على تعيين القضاء من اهل الكتاب ، مثلا : إن القاضي بعد فتح مصر ولي القضاء قضاة بين النصارى ليحكموا بين ديانائهم ، ولما بلغ ذلك عمر ابن الخطاب أقرة .[١]

٣_دليل عقلي : إن القول يجوز تولية غير المسلم القضاء بين أهل ديانته نوع من التسامح بين المسلمين واهل الذمة.[٢]

ثانيا : الحرية : اشترط جمهور العلماء هذا الشرط لأن الرق كان موجودا في عصورهم [٣] وعللوا في ذلك أن العبد مشغول خدمة سيده فلا ينفرغ لمصلحةالأمة [٤] وذهب ابن حرم الطاهري بعدم اشتراط الحرية واستدل في رايه هذا ان القضاء هو نوع من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والرق كسائر أفراد الأمة مخاطب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [٥] . واستدل ايضا بقوله تعالى :( إن الله يامركم ان تؤدو الأمانات إلى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )[٦]. والعبد داخل في هذا الخطاب الرباني كسائر العباد الخاضعة لأمر الله جل وعلا .

قال ابن كثير :" وهذا يعم جميع الامانات الواجبة علي الإنسان من حقوق الله عز وجل على العبادة من الصلوات ، والزكاة ، والصيام ،والكفارات ،والنذور، وعير ذلك مما هو موتمن عليه ولايطلع عليه العباد من حقوق وحقوق العباد " [٧]

---

[١]– القضاء الإداري، ص ،(٤)، بحوث فقهية ص (٦٨)

[٢]– المصدر السابق ،ص (٤٤).

[٣]– إن هذا الحكم لا وجود له في هذا الزمان إلا ما نذر وشد.

[٤]– الروض المربع ،(٣٨٥/٣).

[٥]– المحلي بالاثار (٦٣١/١٠)،القضاء في عهد عمر (٢٩/١) بحوث فقهية ،ص (٩٨).

[٦]– سورة النساء،الآية (٥٨).

[٧]- تفسير القرآن العظيم،(٦٧٣/١).

ثالثا : الذكوريه : هذا الشرط محل اختلاف بين اهل العلم قديما وحديثا ، فذهب الجمهور[١] انه لايجوز تولية المرأة القضاء في أي نوع من اونواع القضايا ،سواء اكان قضايا بالأموال ام الحدود والقصاص والعرض أقوال الجمهور والأحناف وأدلتهم والمناقشة عليها بإيجاز .

**ادلة الجمهور :**

استدل الجمهور بأدلة من الكتاب والسنة والعقل .

أولا : الكتاب : قال تعالي : ( الرجال قوامون على النساءبما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب).[٢]

وجه الاستدلال من الآية : ان الآية اقترنت حصر القوامة في الرجال وذلك لأن قواعد اللغة العربية

تقتضي أن المبتدأ يلام الجنس يقصر الخير "[٣].

ثانيا : أدلة من السنة : حديث أبي بكر رضي الله عنه انه قال : نفعنى الله بكلمة سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لن يفلح قوم ولو امرهم أمراة".[٤]

وجه الاستدلال من الحديث : انه اخبرنا بعدم الفلاح والسعادة قوم ولو عليهم امرأة ،ولاشك أن عدم الفلاح ضرر يجب اجتنابة " لا ضر ولاضرار " [٥]

فيجب اجتناب يؤدي إليه الضرر وقال الاصوليون " الضرر يدفع قبل وقوعه".[٦]

---

[١]- نقصد ذلك المالكية والشافعية والحنابلة والإمام زفر من الأحناف والشيعة الزيدية والإباضية انظر: تفصيل ذلك في شرائع الإسلام ،لأبي جعفر (٥٦٧/٤) ، رسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة ، تفصيل ذلك في الشرائع الإسلام، لأبي جعفر (٥٦٧/٤) ، ورسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة، لمحمد ابن الحسن (١١٧/١٧)، مواهب الجليل ،(٨٧/٦)،الأحكام السلطانيه للماوردي ص (٧٢)

[٢]- سورةالنساء الآية (٣٤)

[٣]- تفسير القرآن العظيم ،(٦٤١/١_٦٤٢) سبل السلام(١٦٩/٤، رقم الحديث (٥٣٩٠) بحوث فقهية، ص (١٢٨ )تفسير البغوي (٥٣٤/٤)

[٤]– أخرجه البخاري برفم (٤٤٢٥) الترمدي في كتاب القضاء برقم(٢٢٦٢)النسائى في كتاب القضاء باب النهي عن استعمال النساء فى الحكم برقم ، (٥٣٩٠) ، ص (٨٣٠).

[٥]– الوجير في شرح القواعد الفقهية، د. عبد الكريم زيدان ،(٨٥)

[٦]– المصدر السابق

أسباب المنع والسر في منع المراة من الولاية نقصان دينها ،وهي علة منصوصة في السنة الصحيحة ، وهو شئ من لوازم المرأة لا تنفك عنها ، دليل ماقلنا قول صلى الله عليه وسلم :" ما رأيت من ناقصات عقل ودين للب الرجل الحازم منكن ، قلت يا رسول الله مانقصات ديننا وعقلنا ؟ قال أليس تمكث إحداكن ...".[1]

**مناقشة الأحناف لأدلة الجمهور:**

**ناقش الأحناف لأدلة الجمهور كما ياتي :**

١-أما المراد بقوامة الرجل في الآية الكريمة ليس المراد بها القوامة التى تشتمل القضاء وغيره من الأموال بل المراد هنا قوامة خاصة وهي قوامة رب الأسرة عليها في الولاية الاسرة التي أشار اليها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : الرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعية وعدم جواز حمل الآيه على القوامة الأسرة أسباب ثلاثة:

**أولا : سبب نزول الآية** : فقد روى عن سعد بن الربيع[2] أنه نشزت امراته فلطمها فأتت النبي _صلى الله عليه وسلم_ شاكية فقال بينهما القصاص فانزل الله: (لاتجعل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه)[3]

**ثانيا : ترتيب الآيه وسياقها** : فإن فيها الإشارة إلى المهر والنفقات التى يتحملها الرجل كقوله تعالى :(وبما أنفقو امن أموالهم) ،وفيها اشارة ايضا الى ما يجب على زوجته من طاعة وامانه لقوله تعلى :(فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ الله) وفيها اشارة الى السلطة المخوله للارواج على زوجاتهم وهو قوله تعالى (اللاتي تخافون نشوزهن فعطو هن واهجروهن )[4]

---

[1]- البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم برقم (٦) ،(٧٨/١).

[2]- ستأتي ترجمه .

[3]- سورة طه، الآية (١١٤) .

[4]- سورة النساء ،الآيه (٣٤)

**ثالثا:صلاحية المراة للولا يات الحاصة** :فالاية لاتفيد العموم ,انها تصح الو لاياتالخا صة كو صبة اليتتم وناظرة مال الوقف,لانها قادرة على أن تقوم بامور هذهلاالولايةما دا مت المراةفا درة في تنفيذ الولاية العامة .

**ادلة الاحناف :استدل الاحناف: دليل من الكتاب :**

**اولا. اما الكتاب :** فقوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء بمافضل الله بعضهم على بعض )[1], ان المراد بالقوامة في الاية ليس المرادبها الفوامة التي تشمل القضاء وغيره , بل المراد هنا حاصه وهي قوغمة رب الاسرة عليها .

**ثانيا : أدلة العقلية فقالوا** : صلاحية المرأة لولايات الخاصة لأنها تصلح أن تكون وصية على اليتيم وتصلح أن تكون ناظرة لمال الوقف؛ لأنها قادر على ان تقوم بأ مور هذه الولاية جاز إسنادها إليها: فكذلك جاز لها إسناد الولايات إليها مادام في مناط الحكم ولاداعي لخصوصية الولاية للرجال مادام تحقق أهداف الولاية.[2]

**مناقشة الجمهور للآية** :( الرجال قوامون على النساء ).[3] إذ الآية أفادت حضر القوامة في الرجال وذلك لأن قواعد اللغة العربية [4] .تقتضتى أن المبتدأ المعرف يلام الجنس يقصر الخبر، وهذا يستلزم أنه لايجوز ولاتصح ولاية المرأة على القضاء ،وإلا كان ألنساء قوامة على الرجال وهذا يتعارض مع نص الآية .

**مناقشة الجمهور : للدليل العقلي** : أما قياس الولايات العامة على الولايات الخاصة فهذا قياس باطل لأن الو لايه الخا صة يكففى فيها مجرد القدرة ،اما الولاية العامة فإنها تحتاج الى

---

[1]– سورة النساء ،الآيه (٣٤)

[2]– بحوث فقهية ص (١١٩

[3]– سورة النساء الآية (٣٤)

[4]– نظام القضاء في الإسلام د.إبرهيم عبد الحميد ص (٣١_٣٢)

قدرة عالية تتناسر مع كنزة أعباء هذه الولاية , وتشعبها ,وإذا وجدت الانو ثة فقد وحد المانع من تو لي الولا يات العامة .

رأي إبن جرير [١] وابن حزم ([٢]) والشيخ محمد العزالي [٣] :

وذهب ابن جرير , وابن حزم،والشيخ محمد العز الي جواز ولاية المرأة في جميع الحالات قيا سا علي جوار شها دتها وفتيا تها [٤] فأصرحهم هو الشيخ الفرالي قائلا : إن القضية ليست قضية الأنوثة وإنما القضية قضية المقفرة والطاقة ، إقرأ شئت قضية بلقيس ملكة سبأ عندما وجهت إلى حيثها ما ور عليها من نبي سليمان واستثارت رجال دولتها الدين سارعوا إلى مساندتها فيأي قرار تتخذه قائلين :( نحن أولوا قوة أولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماتأمرين).[٥]. ولم تغتر المرأة الواعية بقولها ولابطاعة قومها بل قالت :( رب إني ظلمت نفسي

---

[١]– هو محمد ابن جرير بن يزيد بن خالد، ولد سنة (٢٢٤) هجرى في بغداد، وكان في بعداد أمره مقلدا لمذهب الإمام الشافعي، ثم أصبح مجتهدا مستقلا، له تلاميذ ومقلدود، وله مؤلفات شهيرة منها :"جامع البيان عن تأويل أي القرآن "،" اختلاف الفقهاء في الفقه المقارن " ،" تاريخ الطبري". توفي سنة (٣١٠) هجرى ،(٩٢٣ م ) ، الأعلام،(٦٩/٦) .

٤– تقد مت الترجمته

[٣]– هو: الشيخ محمد الغزالي، ولد سنة (١٩١٧ م)، حفظ القرآن وهو دون العاشرة من عمره، تخرج في آلآزهر سنة (١٩٤١)، وهوأحد أبرز الدعاة في هذا العصر، وعرف با لوسطية والاعتدال كما اشهر بالنقد العلمي ،وقد عاش مع كتاب الله تعالى إلي أن وافته المنيه وهو يشترك في ندوة علمية في مكة المكرمه، وله مؤلفات فوف ستين منها:" المحور الخمس للقران؛" وكيف نتعامل مع القران"،؛ مشكلات في طريق الحياة الاسلامبة "،" الدعوة الاتسلامبة،؛" هموم الداعية "،" الحق مر "،" جد د حياتك "،" ركائز الأيمان "،" فقه السيرة "،" فذائف الحق " " السنة النبوية"، وقد سبب هذا الكتاب ضجة كبيرة في أو ساط الدعاة . وفد خدم الشيخ للاسلام وأهله خدمة جليلة ، وإذا أرد ت معرفة منهجه ومذهبيه في الدعوة الإسلامية ، راجع كتاب الدكتور : يوسف القرضاوي ،" الشيخ محمد الغزالي كما عرفته في نفص قرن،"الغرالي في مجلس الانصاف "للشيخ عائض القرني .

[٤]– بداية المجتهد (٩٤/٤) ، الروض المربع ، (٤٣٠/٣) ، الحاوي الكبير (١٥٦/١٦) ،رد المختار لابن عابدين ، (٣٨/٨) ، المحلى بالآثار . (٣٥٨/٨_٣٦١).

[٥]– سورة النمل، الآيه (٣٢).

وأسلمت نفسي مع سليمان لله رب العالمين) .[1]هل خاب قوم ولو أمرهم إمرأة من هذا الصنف النفيس ؟ إن هذه المرأة أشرف من الرجل "[2]

الشيخ خالف في باب الحدود والقصاص قائلا: وإن كان النصوص يسرقون البيوت ليلا أونهارا فما معنى رفض شهادة المرأة في حد السرقة ؟ وإذا كان العدوان على النفس والأطراف يقع كثيرا بمشهد االنساء فما معنى رفض شهادة المرأة ترى المرأة مصرع أهلها أوأقرب الناس إليها ثم يرفض شهادتها ؟" [3] مناقشة :ويرد على الشيخ : ولما منع الشارع الأنوثة في إمامة الصلوات مع حوارإمامة الفاسق كان المنع من القضاء الذي لايصلح في الفاسق أولى ، ولأن من لم ينفد حكمه في الحدود لم ينفد حكمه في غير الحدود[4]. أما جواز فتيا ها وشهادتها فلانه لا ولاية فيها فلا تمنع منها الأنوثة وكذلك تقليد الخنثى لايصلح الجواز ان يكون امرأة زال أشكاله وإن بات رجلا صح تقليد " [5]

القول المختار : بين الآراء التى وردت في مصمار لولية المرأة القضاء فإن رأي الأحناف ينفق مع الواقع الحالى في المصالح المرسلة . لأن الشريعة هي الميزان في هذه المصالح والمفاسد .

قال ابن تيمية :إذا تعارض المصالح والمفا سد والحسات والسيئات اوتزا حمت, فإنه يجب الراجح منهمها إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وان كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدته فينظر في العارض له فإن كان الذي بفوت من المصالح أو يحصل من مفاسد أكثر لم يكن مامورا به بل يكون محرما إذا

---

[1]– سورة النمل، الآيه (٤٤).

[2]- السنة النبوية ص ، (٤٩_٥٠)

[3]– المصدر السابق، ص (٥٨)

[4]– الحاوي الكبير ، (١٥٦/١٦) .

[5]– المصدر السابق نفس الصفحة .

كانت مفسدته أكثر من مصلحته' لكن باعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو ميزان الشريعة فمتى قدرالانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها والااجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر"[1].

القول المختار: بين الآراء الثلاثة التي وردت في مضمار تولية المرأة القضاء، فإن رأي الأحناف يتفق مع الواقع الحالي في المصالح المرسلة، لأن الشريعة هي الميزان في تقدير المصالح والمفاسد قال ابن تيمية: وإذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحته ودفع مفسدته فينظر في العارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن باعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو ميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر.[2] فبناء على هذه القاعدة وغيرها فإن المرأة قادرة على فصل الخصومات والمنازعات القضائية على الصورة المطلوبة، وإن كان يعتريها بعض الأمور الطبيعية كالحيض الذي يجعلها مريضة وكذلك الحمل والنفاس والرضاع وهذا يؤثر عملها القضائي، ومما يعتريها أيضاً النسيان، قال تعالى:( فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى)[3]وقد علل القرآن بذلك أن المرأة قد تنسى أو تحار أو

[1]– مجموع فتاوى ،(١٢٩/٢٨) .

[2]– مجموع فتاوى (١٢٩/٢٨).

[3]- سورة البقرة ٢٨٢

يشتبه عليها وجه الحق وعندما تكون معها امرأة أخرى فسوف يتعاونان على الأدلاء بالحقيقة الكاملة[1]. فإذا أباح الشارع أن تكون مفتية، فذلك القضاء عند الحاجة والضرورة.

قال عز الدين عبد السلام[2]: "ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاداً أو عرفاناً فإن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها.[3] فإن هذا العصر أبرزت المرأة على قدرها في تفصيل الحكم القضائي والوظيفي ولا يخفى على أحد ضرورة ذلك، لا سيما الأمور القضائية الخاصة التي لا يطلع عليها إلا النساء (كالعيوب في الأعضاء التناسلية) فمثل هذه الظروف أولى أن تفوض إليها للقضاء لأن المقصود والهدف الأساسي من القضاء هو إزالة الضرر وإحقاق المصلحة.

وإذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد جوزه إن تعذر منع، ثم إن المرأة نصف المجتمع وتعطيلها يعتبر تعطيل الأمة وإن قصورها في البيت يعتبر بطالة ومن حقها أن تعمل وتكسب، والقضاء كسب كما أن عملها في خارج المنزل يحقق لها استقلالاً

---

[1]– السنبة النبوية للغزالي، ص٥٨.

[2]– هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي قاسم بن الحسن الدمشقي الشافعي، ولد سنة (٥٧٧هـ) الملقب بسلطان العلماء فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. وأهم مؤلفاته: "الإلمام في أدلة الأحكام" و"قواعد الشريعة"، "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، "الغاية في اختصار النهاية" و"مقاصد الشريعة" توفي سنة (٦٦٠هـ)، الأعلام (٢١/٤).

[3]– قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٤٧/١). وقد فصل القول الشيخ عبد الرحمن في كتابه "القواعد الفقهية" المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين، ص(٣٢٩)، ومفتاح دار السعادة، لابن قيم الجوزية، ص(٣٥٠).

اقتصادياً لتنفع به أهلها والمحتاجين من الفقراء ما يكسب لها الثواب العظيم عنده الله. وتساعد زوجها إن كان فقيراً أو إذا كان دخله قليلاً وتعمل ذلك بقيود وضوابط شرعية.[1]

ولكن المرأة لا يجوز أن تولي الولاية العظمى وفي الحدود والقصاص، فالنصوص صريحة في عدم جواز ذلك: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم ..." كما يجب أن ننظر ولاية القضاء بمنظور شرعي والانقياد له وعدم التأثر على المناهج العربية.

**رابعاً: الاجتهاد**[2]

ويمكن أن يقسم إلى رأيين:

الرأي الأول: اشتراط الاجتهاد في القاضي ما يراه بعض المالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية[3] فلا يتولى القضاء جاهل بالأحكام الشرعية ولا مقلد وهذا من يحفظ مذهب إمامه غير أنه لا يعرف بغوامضه، ويكون قاصراً عن تقرير أدلته.

الرأي الثاني: لا يشترط الاجتهاد في القاضي وإليه ذهب الأحناف وبعض المالكية وقالوا: الاجتهاد ليس شرطاً بل يشترط عنده العلم.[4]

---

[1]– تفسير آيات الأحكام للجصاص، (٦٢١/١ – ٢٢٩)، وسائل الإثبات د.محمد الزحيلي (١٩٧/١)، والقواعد الفقهية د.أحمد علي الندوي، ص(٣١٢)، عمل المرأة القانونية د.أبو مدين الطيب البشير، ص(٨٩ – ٩٩)، رسالة الدكتوراه بجامعة إفريقيا العالمية كلية الشريعة والقانون عام (٢٠٠٢م – ١٤٢٣هـ)، والمدخل الفقهي العام للزرقاء، فقد فصل القول في قضية الضرورة وذكر جميع الواجبات (٩٨٣/٢ – ٩٨٩)، وقواعد في التعامل مع العلماء د.عبد الرحمن بن معلا اللويحقي، ص(١٢٠ – ١٢٣).

[2]– أما البقية الشروط المختلف فيها: السمع، البصر، النطق، الكفاءة، وخوفاً من إطالة التمهيد أرجع القارئ إلى أمهات الكتب الفقهية التي خاضت في هذه الشروط بين مجيز ومانع. انظر: شرح رد المحتار، (٣٨/٨)، الحاوي الكبير، مجموع النووي، المغني (١٦/١٤) الكافي، الشرح الكبير، حاشية الدسوقي.

[3]– شرائع الإسلام (٥٦/٤)، البحر الزخار (١١٩/٦)، شرح المقنع (٤٣١/٦).

[4]– شرح رد المحتار (٣٨/٨)، بداية المجتهد (١٧٦٨/٤)، المعني (١٤/١٤)، القواعد الفقهية لعبد الرحمن ابن عبد المجيد، ص(٣٢٩).

استحسنت أن أذكر أنواع الاجتهاد حتى يكون القاضي (كينياً) على علم تام ومعرفة محل النزاع.
قسم العلماء الاجتهاد إلى ثلاثة أقسام:[1]

**أولاً: الاجتهاد المطلق**

وهو أن يتوافر في الشخص القدرة على استنباط الحكم في جميع الأبواب بحيث يستطيع أن يفتي في العبادات والمعاملات من بيع وإجارة ورهن وشفعة وغيرها، كعلماء الصحابة والأئمة الأربعة.

**ثانياً: اجتهاد المذهب**

وهو أن يكون متمكناً في معرفة الأحكام في الوقائع التي لم يرد فيها نص عن إمام مذهبه بطريق التخريج على النصوص، والقواعد المنقولة عن هذا الإمام فاجتهاده لا يخرج عن دائرة المذهب ومجتهدي المذهب، كابن القاسم وأشهب في المذهب المالي وابن الهمام في المذهب الحنفي والغزالي والنووي والماوردي في المذهب الشافعي، وابن عقيل، وابن الخطاب، في المذهب الحنبلي.

**ثالثاً: الاجتهاد العمومي**

وهو أن يكون متمكناً في ترجيح قول إمام المذهب على قول آخر، أو ترجيح ما قاله الإمام أو ما قاله تلميذه.

وقد اشترط العلماء في الاجتهاد المطلق شروط منها:

أولاً: لا بد أن يكون عارفاً من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام، ولا يشترط أن يكون حافظاً للآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة عن ظهر القلب، بل يكفي لأن يكون عارفاً بمواضع أحكام القرآن والسنة لكي يرجع إليها عند الحاجة ويجب عليه أن يعرف خاص القرآن وخاص السنة

[1]– مغني المحتاج، (٦/٢٧٥).

وعمومها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومبينها، ويعرف الناسخ والمنسوخ والنص[1] والظاهر[2] والمحكم[3] والسنة المتواترة.

ثانياً: أن يكون عالماً بلسان العرب لغة ونحواً وصرفاً وبلاغة؛ لأنه لابد منه في فهم الكتاب والسنة.

ثالثاً: أن يعرف أقوال العلماء من الصحابة ومن بعدهم إجماعاً واختلافاً فلا يخالفهم في اجتهادهم إذا أجمعوا على حكم من الأحكام.

رابعاً: أن يكون عارفاً بالقياس[4] وشروطه وأنواعه، فيعرف القياس الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق بين المقيس والمقاس عليه، وفي هذه الأمور خاض العلماء عليها وكثر حولها النقاش والاستدراكات، وعرض الأدلة ولمن أراد ذلك فليراجع أمهات الكتب الأصولية والقواعد الفقهية والله أعلم.

**آداب القاضي :**

**أولا** : فعلى القاضي ان يستند إلى كتاب الله وسنة نبيه أوفي إجماع الأمة يراعي قواعد الإسلام وكلياته فيجتهد في فهم النصوص وتطبيقاتها علي الوقائع المعروضة أمام القاضي ، فإن المقصود من القضاء إيضا الحقوق إلى ذوبها وقمع الظالمين وتوبيحهم .

فإذا اجتهد في واقعة فاصاب فله أجرين، وإذا اخطأ فله أجر. قال تعالى : (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وطيعوا الرسول والي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن

---

[1]– النص هو: ما دل بنفس لفظه وصيغه على المعنى دون توقف على أمر خارجي، الوجيز، ص(٣٤٠).

[2]– الظاهر هو: دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه في نفس صيغة، المصدر السابق، ص٣٥٦.

[3]– الحكم هو: ما دل على معناه الذي لا يقبل إبطالاً، علم أصول الفقه، ص١٦٣، الوجيز، ص٣٦٨.

[4]– القياس عند الأصوليين هو: إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم المتشابه ... إرشاد الفحول (١٩٨/١).

كنتم تؤمنون با لله واليوم الآخر )[1] وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه ان يرد النازع في ذلك إلى الكتاب والسنة[2]. فإذا لم يجد نصا أو سنة أو إجماع الأمة فإنه يجتهد .

**ثانيا : الأخد بالأدلة:** فإن الإسلام بين أحكامه على الأدلة الظاهرة، ولا يأخذ بنظرية الشك **قال ابن حزم الظاهري:** لايحل الامتحان في شيء من الاشياء يضرب ولا يسخن ولا بتهديد، لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ثابتة ولا إجماع، ولاا يحل اخذ شيء من الدين إلا النصوص.[3]

ثالثا: المواجهة بين الخصمين وإحضارهما واعطاء كل واحد منهما حق الدفاع عن نفسه وإثبات دعوته بالأدلة والبراهين والحجج .

رابعا: الصلح بين المتخاصمين : حرص الإسلام على نقاء الاخوة الإيمان القوية المثبتة بين المسلمين، وامر بإزالة جمع بين العراقيل ، قال تعالى:( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما[4]. وقال:(وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أوإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير )[5]. وإذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها فلها أن تصلح معه كان تسقط عنه حقها أو بعض من النفقة أو الكسوة فالصلح خير من الفراق[6].

وقوله تعالى :( لاخيرفي كثير من نجواهم إلامن أمر بصدقة أومعروف أو إصلاح بين الناس)[7]

---

[1]- سورة النساء ، الآيه (٥٩)

[2]- تفسير ابن كثير ،(٦٧٧/١).

[3]- المحلي بالآثار ،(٤٠/١٠) .

[4]- سورة الحجرات ،الآيه (٩) .

[5]- سورة النساء ، الآيه (١٢٨) .

[6]- تفسير ابن كثير ،(٦٣٦/١) .

[7]- سورة النساء ، الآيه (٢١٤) .

**نقص الحكم وأثره:** القاضي ملزم ومقيد بما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ(49) [1]. فإذا لم يلتزم القاضي في هذه النصوص الصريحة وغيرها فإن حكمه سيكون باطلاً، فإذا حكم باجتهاده ثم تبين له خلاف ما حكم رجعه إلى الصواب وقد بيّنت تفصيل ذلك رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: "لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت نفسك فيه اليوم فهديت لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، لأنه خطاء فوجب الرجوع". [2] قال ابن القيم: "يراد أنك إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة أخرى فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته، فإن الاجتهاد قد يتغير ولا يكون الاجتهاد الأول مانعاً من العمل بالثاني، إذا ظهر أنه الحق فإن الحق أولى بالإيثار، لأنه تقديم سابق على الباطل. [3]

إن المسائل الاجتهادية إذا حكم فيها بحكم فلا ينقضه، فإذا تجدد له اجتهاد آخر فإنه يحكم به في القضايا اللاحقة، فإن هيبة القاضي مهمة جداً، أما القضايا المنصوص عليها في الكتاب والسنة أو مجمع عليها فإنه إذا حكم بخلافها فإنه ينقض باتفاق أهل العلم. قال ابن قدامة: "ينقض إذا خالف نصاً أو إجماعاً فإن قضاءه لم يصادق شرط المعتبر في الشرع فوجب نقضه كما لو خالف الإجماع". [4] والله أعلم.

---

[1] – سورة المائدة، الآية: ٤٩.

[2] – إعلام الموقعين، (١١٩/١ – ١٢٢).

[3] – المصدر السابق، الصفحة نفسها.

[4] – المغني، (٥٦/٩)، المقنع (٦١٣/٣)، وراجع تفصيل ذلك الحاوي الكبير، (١٧١/١٦١ – ١٧٤)، القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين، لأبي عبد الرحمن بن عبد المجيد، ص(٣٢٣)، الأم (٢٧٦/٦) و(٢٨٠).

## المبحث الثالث

## مجال التحكيم في مسائل التفريق وعلاقة التحكيم بالقضاء

**تقديم:**

إن التحكيم طريقة من طرق إنهاء النزاع المعروفة قديماً وحديثاً، والتي يلجأ لها الناس في قضايا متعددة ولأسباب متنوعة، وإنني في هذه السطور سأعمل على تسليط الضوء على بعض عناصر هذا الموضوع ذات العلاقة بقضايا التفريق، ووفق هذا التحديد فسأعرض التحكيم في المطالب التالية:

أولاً: في تعريف التحكيم وطريقة تعيين مرجعه

ثانياً: علاقة التحكيم بالقضاء

ثالثاً: مجال التحكيم في مسائل التفري

### تعريف التحكيم وطريقة تعيين مرجعه

#### تعريف التحكيم

التحكيم لغة:[1]

التحكيم لغة من كلمة أصلها حكم، والتحكيم مصدر للفعل حكم، وقيل حكمه في ماله تحكيماً إذا جعل إليه الحكم فيه فاحتكم عليه في ذلك، والحكم في اللغة كذلك بمعنى القضاء، ويأتي بمعنى المنع، قيل حكمت الرجل تحكيماً إذا منعته عما يريد، ولعل المعنى الأقرب في معاجم اللغة

[1]– مختار الصحاح: مادة حكم، الخطابي، الغريب، ج٢، ص٤٦٢.

للمعنى الذي نريد هو جعل الحكم إلى جهة ما بمعنى تحكيمها، وكذلك المنع ومنه المنع من الخصومة.

**التحكيم اصطلاحاً:**

عرفت مجلة الأحكام العدلية التحكيم بأنه اتخاذ الخصمين شخصاً آخر برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما، والتحكيم تدور فكرته على أشياء هي:

١- اتفاق وتراضٍ من قبل الخصوم على الجهة الحاكمة.

٢- جهة حاكمة.

٣- موضوع التحكيم، وهو الخصومة في موضوع ومجال ما.

٤- نتيجة التحكيم وهو الحكم الصادر من الجهة المحكمة المنهي للخصومة المعروضة.

وإن أي تعريف يشمل هذه الأركان فإنه يفي بالغرض المراد، حيث التدقيق اللفظي في التعريفات ليس مرادنا في هذا الأمر.

وقد عرفه د.إبراهيم حرب محيسن قائلاً: "هو تولية الخصمين حكماً بينهما للحكم فيما تنازعا فيه".

والفقهاء قديماً عرفوا التحكيم بمفهومه أكثر من تعريفه بحده فنجدهم ذكروا في بداية أبواب التحكيم ما مثاله: "فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصاً صالحاً للقضاء نفذ حكمه".

**طريقة تعيين المحكم**

**المحكم له طريقان في التعيين:**

الطريقة الأولى: أن يختار الطرفان المتنازعان المحكم بكامل رضاهما سواء كان فرداً أو أشخاصاً متعددين، وبعد اختيارهما له يعطى صفة الحكم، ويباشر مهام عمله في حل الخصومة بينهما وهذا التعيين هو المشهور في باب التحكيم.

الطريقة الأخرى: أن يختار القاضي أو الحاكم الحكم ويرسل الخصومة له، وهذا وإن كان اسمه حكماً إلا أنه بهذه الصفة يأخذ صفة التولية الرسمية ممن له التولية إن كان مأذوناً فيها، وهو بهذا يكون منابأً عن القاضي أو الإمام الذي ولاه.

والمعنى المراد من التحكيم في اصطلاح الفقهاء هو الأول لما عرفوه ذكروا أن شرطة تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما، ومعنى التولية أن يستمد الحكم سلطته في الفصل بين الخصمين منهما، ولذا فإنه لا بد من وجود هذه التولية ابتداءً، ثم تحقق القبول من قبل الحكم ثانياً، فالرضا عنصر متبادل بين الأطراف ثلاثتهما.[1]

**مجال التحكيم في مسائل التفريق**

**مجال التحكيم في الفقه**

تعددت أقوال الفقهاء في جواز عرض الخصوم مسائل التفريق على غير القضاء من المحكمين على النحو الآتي:

القول الأول: يجوز نظر المحكمين في مسائل التفريق بين الزوجين، وإثبات الطلاق وحكمها في ذلك كحكمهما في غيره من الأمور التي يجوز فيها التحكيم.

وقال بذلك من أهل العلم كل من الحنفية والشافعية والحنابلة.

[1]– الدوري، عقد التحكيم، ص١١٢.

ومن أمثلة ما ذكر الحنفية، حكم المحكم في الطلاق المضاف فإنه ينفذ عندهم، لكن لا يفتى به، وذكروا مثالاً على ذلك لو قال رجل لامرأته أنت علي حرام ونوى الطلاق دون الثلاث فحكما رجلين، فحكم أحدهما بأنها بائن، وحكم الآخر بأنها بائن بالثلاث لم يجز لأنهما لم يجتمعا على أمر واحد.

والاستدلال من هذا النصل الفقهي في موضوعه الذي خاض في مسألة من مسائل الطلاق.

وضربوا مثالاً آخر في من مس صهرته بشهوة فانتشر لها، فحكم الزوجان رجلاً ليحكم بينهما بالحل على مذهب الشافعي فإنه يصير حكماً بينهما، لكن الصحيح عندهم أن حكم المحكم في مثل هذه لا ينفذ.

القول الثاني: لا يجوز نظر المحكمين في مسائل التفريق أصالة، وذهب إلى هذا الرأي من أهل العلم المالكية، أما التحكيم في الشقاق بين الزوجين فإن الأصل فيه أنه تحكيم في الصلح لا بالطلاق أصالة.

**علاقة لتحكيم بالقضاء**

**وللإلمام بهذه العلاقة سنبحث الأمر من الجهات التالية:**

الجهة الأولى: التكييف الفقهي والقانوني الخاص بالتحكيم نسبة إلى القضاء

الجهة الثانية: صفة الأحكام الصادرة عن المحكمين

الجهة الثالثة: تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمين

إن الناظر المدقق في طبيعة التحكيم ومفهومه لدى الفقهاء يلحظ أن الفقهاء جعلوه بمنزلة تولية الحاكم للقاضي، وهي من باب الولايات إلا أنها ولاية خاصة في خصومة معينة بين خصوم

محددين، قال الطحاوي عن الحكم (هو بمنزلة القاضي)[١]، وقال ابن الهمام (هذا أيضاً من فروع القضاء)[٢] يعني بذلك التحكيم، (والمحكم أحط رتبة من القاضي)[٣]، وقال: (لكل واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما، لأنه مقلد من جهتها إذ هما الموليان له فلهما عزله قبل أن يحكم كما أن للسلطان أن يعزل القاضي قبل أن يحكم).[٤]

وقال الشربيني (والمحكم لا ينفذ حكمه إلا على راضٍ به قبل حكمه، لأن رضا الخصمين هو المثبت للولاية)[٥]، وقال البهوتي: (وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء بينها فحكم ... فهو كحاكم الإمام).[٦]

وهذا التكييف هو من جهة الخصمين للمحكم فإنه تولية من قبلهما في شأن يخصهما، فلا بد من رضاهما بذلك ثم قبول من الآخر، والتحكيم كما يرى الدكتور قحطان الدوري هو عقد بين المتخاصمين والمحكم يحتاج إلى إيجاب منهما وقبول منه وهو عقد له سائر أحكام العقود من الشروط الخاصة والعامة.

ولكن ما صفة هذا العقد من جهة ارتباطه بين المتخاصمين والمحكم، هل هو عقد لازم للطرفين أم غير لازم؟، إن الجاري على قواعد الفقهاء ف تولية الإمام للقاضي أن له عزله قبل تمام الحكم، والمحكم له نفس الحكم من هذه الناحية عندهم، لأن ذلك في حق المحكم يعتبر من باب التعيين له، وهو توكيل من قبلهما له، لكن تبقى مسألة معالجة النفقات التي يكون قد تكبدها الحكم في إجراءات التحكيم.

---

[١]- الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، ج٤، ص٢٠٤.

[٢]- ابن الهمام، فتح القدير: ج٧، ص٣١٥.

[٣]- المرجع السابق.

[٤]- المرجع السابق: ج٧، ص٣١٧.

[٥]- الشربيني، مغني المحتاج، ج٤، ص٣٧٩.

[٦]- البهوتي، كشاف القناع: ج٦، ص٣٠٨.

أما صفة التحكيم بين الطرفين المتخاصمين فما حكم لزومه بينهما؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

**القول الأول:**

إن عقد التحكيم لازم للطرفين من جهة والمحكم من جهة أخرى وذلك إذا بدأ بالحكم أي في حال انتهاء عملية التحكيم والبدء بالنطق بالحكم فمتى ما بدأ بالنطق بالحكم كان لازماً لا يجوز للخصمين الرجوع فيه لو اتفقا على ذلك. وذهب إلى هذا القول الحنفية.

**القول الثاني:**

عقد التحكيم لازم للطرفين إذا أتم المحكم الحكم، وقبل ذلك لا يلزم، واستدامة الرضا بالتحكيم إلى تمام الحكم يعتبر من الشروط الواجب توافرها. وذهب إلى هذا القول الشافعية وهو وجهه عند الحنابلة.

## الفصل الثاني

## مفهوم التفريق القضائي

التفريق القضاء عبارة عن صفة وموصوف، فالموصوف هو التفريق، وصفته انه قضائي ولكي نلج في مضمون هذا البحث لا بد وان نتعرف حقيقته والتي مرتكزها الفرقة بين الزوجين بواسطة القضاء، وللوصول إلى حقيقة المعنى المراد فنقدم له بتعريف للتفريق.

### المبحث الأول

### أولا: تعريف التفريق لغة واصطلاحا

التفريق مصدر، فرق واصل الكلمة فرق بين الشيئين على وزن نصر، والفرقة اسم من فارقة مفارقة وفراقا[١].

والفرق خلاف الجمع والاسم فرقة وتفريق، والمصدر فرق فرقة للافتراق، وفارق الشيء باينه، والفرق الفصل بين الشيئين[٢].

ويلاحظ من مراجعة المعاجم اللغوية أن المعنى اللغوي للتفريق يراد به الفصل بين الشيئين المبا ينة بينهما، وقد وردت شواهد في القرآن الكريم لمعنى الفرقة حيث وردت الفرقة بين الزوجين بمختلف أشتقاقاتها اللفظية في ثلاثة مواضع هي :

أولا: قوله تعالى عن السحرة : ( فيتعلون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه)[٣].

الثاني: قوله تعالى : (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف).[٤]

الثالث: قوله تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته).[٥]

---

[١]– مختار الصحاح : مادة فرق .

[٢]– ابن منظور، لسان العرب : مادة فرق .

[٣]– سورة البقرة ،آيه (١٠٢)

[٤]– سورة الطلاق، آيه (٢) .

٥_سورة النساء ، آية (١٣٠).

[٥]-سورة النساء ، آية (١٣٠).

**التفريق في اصطلاح الفقهاء**

الفرق والتفريق مصطلحان فقهيان هما النتيجة العملية للطلاق أو التطليق أوفسخ العقد، وقد اعتني الفقهاء بتعريف الطلاق أكثر من اعتنائهم بتعريف الفرقة أو الفسخ، ولذا فسأحاول الوصول إلى منعى الفرقة اصطلاحا من خلال نظرة الفقهاء إلى معنى الطلاق بالاعتبار الذي ذكرت لأن الطلاق هو أحد نوعي الفرقة.

والفرقة بالمجمل رفع قيد النكاح حالا أومآل،ا أو ما تنحل به عقدة النكاح فينقطع به ما بين الزوجين من علاقة زوجية[١]. فالحنفية يرون أن الفرقة رفع لقيد النكاح[٢]، والشافعية يرون أنها حل لعقد النكاح أو تصرف للزوج يقطع النكاح [٣]، وهي عند المالكية صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجية[٤] أورفع القيد الثابت بالنكاح،

أما الحنابلة فالفرقة عندهم تعني حل قيد النكاح أو بعضه.[٥]

وأشار ابن نجيم في تعليقه على تعريف الحنفية للطلاق منتقدا إياه، انه يتضمن نوعي الفرقة من الطلاق والفسخ، والتفريق الذي انتقده يشملهما فان ذلك يخدم موضوعنا بالاعتبار الكلي ليكون من التعر يفات العامة للفرقة بنوعيها التطليق والفسخ، لأن ابن نجيم بتعليقه قد أشار إلى المعنى المراد للفرقة عند الحنفية بنوعيها وهو ما نريد التوصل إليه، وقد استخدم الفقهاء كابن نجيم وابن الهمام لفظ التفريق مرادفا للتطليق فقد جعلا قول القاضي للزوجين فرقت بينكما عند إياء الزوج الإسلام حال إسلام زوجته وبعد اللعان جعلا ذلك من الطلاق.

---

[١]- علي الخفيف ،فرق النكاح : ص (١)

[٢]- ابن نجيم، البحر الرائق ص ٢٥٢ ج ٤ ،ابن الهمام ، فتح القدير : ص ٤٦٣ ج( ٣) .

[٣]- الشربيني ، مغني المحتاج : ص ٢٧٩ ج (٣)

[٤]- الخطا ب ، مواهب الجليل : ص ١٨ ج (٤) .

[٥]- الزرقاني ، شرح الزرقاني على المو طأ : ص ٢١٦ ج (٣) .

## المبحث الثاني

## أسباب التفريق القضائي

إن اسباب التفريق القضائي كثيرة ولم ترد علي سبيل الحصروإنما وردت على سبيل المثال فالضرر قد يكون تحت العيب الجسماني الذي قد يؤثر على استمرار الحياة الزوجية وقد يكون الضرر تحت الهجر والتى تجعل الحياة الزوجية مستحيلة لما يسببه للزوج الآخر من ضرر، وقد يكون الضرر تحت عدم الإنفاق أي عدم إنفاق الزوج على زوجته على اعتبار ان الزوج هو المكلف شرعا في الإنفاق على زوجته ، وقد يكون الضرر تحت العنف الأسري وما قد يصيب الزوجة أو الزوج من ضرر من جزاء هذا العنف الذي قد ينصب على أحد الزوجين أو على أولادها .

**أسباب طلب التدخل القضائي :**

من ضرورة وجود حهة تطلب التفريق وتستند في طلبها إلى أسباب توجب الفرقة فإن المبحث مخصص لعرض الأسباب التى تدعو كل جهة إلى اللجوء إلى، القضاء طالبة التفريق بدءا من الزوجة ثم الزوج ثم الولي.

**أسباب لجوءالزوج إلى التفريق القضائي :**

إن الزوج يملك إنهاء العقد القائم بينه وبين زوجتة بتطليقها، ودون مراجعة أحد أو توقف قراره على قبول أحد فهو صاحب القرار وصاحب الأمر في ذلك، إلا أنه وفي بعض الحالات قد يلجا إلى القضاء طالبا التفريق دون أن يستخدم حقه في التطليق، ولجوء الزوج إلى هذا النوع من التفريق هـ الذي يثير التساؤل حول الأسباب ما دام ان البديل الأقل جهدا ووقتا متوفر لديه؛ إلا هذا الأمر لا يخلو من فائدة في حق الزوج ويمكن بيان الأسباب كما يلي:

**اولا: ويتعلق بالآثار المالية لقرار التفريق على الزوج**

إن الزوج يعلم يقينا أنه إذا قام بإنهاء العقد بإرادة منفردة منه وتصرف من قبله بالطلاق؛ فإن ذلك سيرتب عليه أعباء مالية تتمثل في حقوق الزوجة المالية الناشئة عن العقد والمتمثلة في مهرها الذي أجرى عليه عقد نكاحها، بالإضافة إلى ما رتبته القوانين الحديثة للأحوال الشخصية من تعويض عن الطلاق، فلذا فإنه يحاول التخلص من هذا الأثر بإيجاد وسيلة لتحمل الزوجة جزءا من التبعة المالية، بإثبات أنها متسببة في الفرقة إذا كان يظن أنه الطرف المتضرر من استمرار عقد النكاح ، وذلك كما يحصل في التفريق للشقاق بين الزوجين بواسطة الحكمين عند المالكية ، فإن للحكمين ان يقررا التفريق، ويحدد مقدار الإساءة المترتبة على كل واحد منهما ، ليتم احتسابها من المهر[1]، وهو ما أخذ به القانون الأردني[2].

**الثاني: ويتعلق بالآثار المعنوية لقرار الطلاق.**

إن قيام الزوج بتطليق زوجته قد يسبب له آثارا معنوية واجتماعية لدى الناس باتهامه بالظلم، وعدم احترام العشرة، الإساءة للزوجة بتطليقها، لدا فإنه يحاول تجاوز ذلك با للجوء إلى القضاء ليضع أسباب الطلاق بين يدي القاضي، طالبا التفريق بموجبها، ليصدر الحكم أخيرا بالتفريق من جهة قضائيه تعفي الزوج من تبعات الطلاق المعنوية.

إضافة إلى أن الزوج قد يرغب في ان تكون أسباب الطلاق معلومة للناس، لكي لا يلام على فعله كما في اللعان أو الإساءة للزوج ماديا ومعنويا.

**الثالث: ويشترك فيه الزوج مع الزوجة، وهو حالة الاشتباه في الحل،** فالفيصل في ذلك القضاء، كما في فساد العقد في الرضاع ، أو طروء ما يفسد العقد يفعل ما يوجب حرمة المصاهرة مثلا، أو حدوث بعض الأفعال من أحد الزوجين التي قد ينسب مرتكبها إلى الردة، فاللجوء إلى القضاء في هذه الحالات هدفه تقرير واقع والتأكد من آثاره.

---

[1]- القاضي عبد الوهاب ، التلقين : ص ٩٧ .

[2]– المادة ١٣٢ من قانون الأحوال الشخصية .

**الرابع: وهو سبب مرتبط بالحاجة إلى رفع الوجود الحسي للعقد الذي تم بين الطرفين،** وإن كان ليس له وجود اعتباري من حيث ترتب الآثار، وليفهم كل طرف عدم حله للآخر ، وتفهم المرأة حلها للأزواج، فإنها كما لايجوز لهما البقاء على العقد الفاسد فإنها لايجوز لها التزوج بآخر ما لم يقرر قضاء فسخ العقد االأول ورفعه حكما [1]، وذلك لعدم تسليط زوجين عليهما، أو لدفع الشبهة والظنون عنهما قانونا وفقها.

**الخامس: ومما يمكن اعتبار من الاسباب،** مما يمكن أن يعتبره الزوج فائدة ناتجة عن الفرقة القضائية، تتعلق باحتساب عدد الطلقات فإن الزوج يملك على زوجته ثلاث طلقات وقد لا يرغب الزوج مع وجود سبب الفرقة بإنقاص عدد الطلقات بينه وبين زوجته أملا بالرجوع إليها مستقبلا ومن باب الاحتياط له، فلا يكون أمامه إلا القضاء وذلك لاعتبار الفرقة فسخا لا طلاقا إلا أن ذلك لا يكون إلابناء على أسباب معينة ، وذلك التفريق بين الزوجين بناء على اختلاف في فساد العقد كنكاح المحرم، فهو واجب الفسخ عند الجمهور [2]، وللزوج أن يطلق بإرادته عند المالكية او بحكم القاضي والنتيجة هي التطليق واحتساب طلقه عليه [3] بينما لا يقبل طلاقه عند الشافعية والحنابلة لفساد العقد ويفسخ دون طلاق بحسب القاعدة عندهم في ذلك [4] وقد تقرر عند المالكية اعتبارة طلاقا لوجود الخلاف الفقهي فيه.

ومن ذلك التفريق للعيب فإن الزوج بعد الدخول إذا وجد عيبا بزوجته يملك أن يطلقها أو أن يرفع الأمر للقاضي للفسخ، وفي كلا الحالين يجب عليه المهر، لكن إن طلق حسبت عليه طلقة وذلك بخلاف الفسخ، ولذا عندما نقل المرتضى رأي الزيدية في المسألة، نقل أن المذهب

---

[1]– الد ميا طي ، اعانة الطا لبين : ج ٣ ص ٣٠٣ .

[2]– الحصني، كفاية الخيار : ص ٣١٦ ؛ ابن النجار ،، منتهى الارادات : ج٢ ص ٩٥ .

[3]– القرافي ،الذخيرة : ج٤ ص ٢١٩ .

[4]– انظر تفصيل ذلك الفصل الثاني من هذه الدراسة ،المبحث الثاني ،منهج الشافعية والحنابله ثالثا ورابعا .

يرى أن الزوج إما أن يمسك او يطلق إذا حصل الدخول، حيث لا تمرة للفسخ حينئذ بل هو والطلاق سيان للزوم المهر، فقدم الجواب على ذلك قائلا: ( فائدته توقى التثليث في الطلاق)[1]

**أسباب لجوء الزوجة إلى التفريق القضائي**

الزوجة تلجأ للتفريق بواسطة القضاء لعدة أسباب نستطيع ان نجملها بما يلي :

**الأول:** أنها لاتملك حل عقدة النكاح بحكم الاصل، حيث أن المالك لحل عقدة النكاح بشكل منفرد هو الزوج لأنه صاحب الحق الأصيل في ذلك.

**الثاني :** عدم تمليك أو تفويض الزوج لها طلاق نفسها سواء بالعقد أو بعده، بمعني أن الزوج لم يعطها هذا الحق الذي يملكه لكي تطلق نفسها نيابة عنه،

**الثالث:** عدم إجابة الزوج طلب المرأة التفريق أو الطلاق؛ سواء كان مأمورا بالإجابة شرعا لوجود السبب أو غير مأمور، فعدم إجابة الزوج لطلب المرأة هو الذي يدفعها إلى القضاء بغية إلزام الزوج بإجابة الطلب أو الحكم بالفرقة جبرا عنه.

**الرابع:** في حالات وجود فرقة بين الزوجين بطلاق أو غيره وفي حال إنكار الزوج وجود يتعلق بالحل والحرمة بين الزوجين.

**الخامس:** في حال اشتباه المرأة في كونها حلالا لزوجها أولا، وذلك في حالات فساد العقد أو طروء مايفسده شرعا فإنها للقضاء ليقررالفصلرفي موضوع الحل والحرمة ظاهر وباطنا بين الزوجين، وعلى سبيل الإلزام خاصة في الحالات المجتهد فيها بين الفقهاء.

**السادس:** تلجأ الزوجة أحيانا للقضاء من أجل المحافظة على جقوقها المالية والتى أنشاها عقد الزواج، حيث ترفض الزوجة أحيانا الوصول إلى اتفاق رصائي مع الزوج على الطلاق

[1]- القاضي عبد الوهاب ، التلقين : ص ٩٧ .

حفاظا علي تلك الحقوق، مع أن الزوج قد يعرض الموافقة على الطلاق مخالعة رضائية أو علي مال اومقابل الإبراء بنوعيه الخاص والعام .

## المبحث الثالث

## أسباب لجوء الولي إلى التفريق القضائي

بما أن الولي ليس طرفا في العقد، إلا انه وبما أعطاه الشارع من حق في إمضاء عقد الزواج أو عدم إمضائهه للأسباب الشرعية المعتبرة كعدم كفاءة الزوج [1] ، فان الشارع قد حافظ على حق الولي وذلك في حال إجزاء العقد دونه لأي سبب من الأسباب ، إذ أعطى الولي في بعض الحالات صلاحيات عدم إمضائه إلا أنه لايستطيع أن يقرر رفع العقد من تلقاء نفسه ، وذلك لانعقادة صورة وحسا ، فلا بد والحالة هذه أن يلجا إلي من له الولاية العامة وهو القضاء طالبا رفع هدا العقد او فسخه أو استكمال ماتم فيه من نقص .

[1] - عدم الكفاءة / مادة ٢٠

## الفصل الثالث

## التكييف الفقهي للتفريق القضائي ومشروعيته

**تمهيد :**

الفرق بحسب التعريف المختار تتضمن الإنشاء من قبل القاضي أو تقرير ثبوتها لديه، فالنوع الثاني وهو الثبوت ينحصر الفعل القضائي فيه أمرين :

**الأول :** في بيان وقوع الفرقة الواقعة من الزوج كأن يكون قد أوقع طلاقا على زوجته وأنكر ذلك ،ثم أثبتت هي ذلك لدى القاضي .

**الثاني:** في تثبيت الانفساخ الحكمي للعقد بموجب النص الشرعي المقرر للفسخ ، كثبوت كون الزوجة أختا للزوج في الرضاعة .

أما النوع الأول وهو أنشاء الفرق، فإما أن يكون بناء على طلب الزوج ، أو بناء على طلب غيره، فإن كان بناء على طلب الزوجة أوالولي ، فإن عمل القاضي في قرار الفرقة هو الوصول إلى إلزام الزوج بإنهاء العقد في حال فساده أو بطلانه من أصله ،والإلزام يكون تبعا لأسباب بحثها القاضي وثبتت لديه ، وعند تحقق الإلزام للزوج فإما أن يستجيب للأمر القضائي فيقوم بالتطليق وعندها يقرر القاضي ثبوت الطلاق الصادر من الزوج، وتنتهي دعوى التفرير بفرقة اختبارية من الزوج، وليس فرقة قضائية.

وإما أن لا يلتزم الزوج بإلزام القاضي ، وعليه وحيث أن القاضي له ولاية عامة وسلطة جبرية ، فيقتضي الأمر منه القيام بالتنفيد الجبري ، إلاان الامر اللأزم تنفيذه في هذه الدعوى يتعلق بالإرادة وبالتلفظ بها، وهذا لا إمكان للإلزام به عند رفض صاحب العلاقة القيام به، ولو تم اللجوء إلى حسبه مثلا فانه قد لا يلتزم ، وعندها وحتي يكون للقضاء فائدته ودوره وأثره ، فلا بد وأن يكون هناك حل علمى عند امتناع الزوج عن التطليق الا ختياري وهذا الحل له طريقان :

**الأول** : إما أن تشكل هناك نيابة حكميه عن الزوج من قبل القاضي تخول هذه النيابة القاضي تطليق الزوجة على زوجها وبالتالى وقوع آثار هذا التطليق قياسا على تطليق الزوج.

**الثاني** : أو يقوم القاضى بإنهاء العقد ورفعه بين الزوجين بما يسمى فسخ العقد وإفهام الطرفين بإنقضائه بينهما . وذلك بحكم الولاية العامة التى تجيز رفع الضرر عن المتضرر . والطريفان هما صورتان لتكييف العمل القضائي النهائي فى دعوى التفريق وهما نتيجة العمل القضائي فيها.

وهذا التقديم هو المدخل لبيان وشرح تفصيلي للتكييف القضائي للتفريق وحتى يصل القاضي إلى قرار بإلزام الزوج طلاق زوجته لابد ان يمر ذلك بمراحل وإجابة على تساؤلات عديدة منها ؛لماذا يلزم القاضي الزوج بالفرقة ؟ ومتى يلزمه بذلك؟

وللحكم على الأشياء كما يقول أهل العلم ضوابط أولها تصور الأشياء تصورا صحيحا ليكون الحكم دقيقا، وبهذا التقديم نرى ضرورة تكييف مفهوم التفريق القضائي فقها، ليصار إلى تحديد مشروعيته ومجالة ، وللوصول إلى قدر سليم من حقيقة التكييف فمن الضروري معرفة وتحقيق قضيتين أساسيتين :

**الاولى** : من صاحب الحق الأصيل في الفرقة بين الزوجين ؟

**الثانية** : مدى السلطة الممنوحة لصاحب الحق الأصيل في إنشاء هذه الفرقة.

وبعد ذلك نلج إلى الفرقة بواسطة القضاء لنرى موقعها من القضيتين المذكورتين، ونضع لها تصوا فقيها واضح المعالم.

## المبحث الأول

## صاحب الحق في الفرق بين الزوجين

إن عقد الزواج يمكن أن نحدد اطرافه ومن له صلة مباشرة به بثلاثة الزوج والزوجة والولي ، ولكل طرف من هذه الاطراف حقوق محددة في عقد الزواج بدء بتأسيسه وتمامه وصولا إلى رفعه إذا اقتضى الامر، وقد أعطى الشارع طرفا واحدا وهو الزوج سلطة التصرف في العقد وفق متقضيات الشرع برفع أحكامه أصالة مع عدم إغفال حق الزوجة والولي في ذلك وفقا لحالات تستو جب رفع العقد وهذا الحق الأصيل نستخلصه من خلال النصوص قرآنا وسنة ومن خلال ماقرره الفقهاء من قواعد وأحكام يمكن أن نوردها كما يلي :

**أولا :** القارئ لنصوص الكتاب المتعلقة بالفرقة بين الزوجين يلاحظ جليا أن الخطاب فيها منسوب إلى الزوج بلفظ الطلاق وقد وردت الآيات بلفظ ( طلقتم النساء ) فى أربعة مواضع هي :

قوله تعالي ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه)[1] وكذلك قوله تعالي :

(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينحكن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف )[2] وكذلك قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على

[1]– سورة البقرة : الآيه (٢٣١)

[2]– سورة البقرة : الآيه (٢٣٢)

المحسنين)[1] وكذلك قوله تعالى :( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقو الله ربكم)[2]

وبلفظ ( فان طلقها) في موضعين في ذات الآية هي قوله تعالي: (فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلاجناح عليهما ان يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله)[3] أما الالفاظ الأخرى فكانت(إن طلقكن ) وألخطاب للنبي عليه السلام في قوله تعالى : (عسى ربه إن طلقكن ان يبدله أزواجا خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات ثائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا )[4]

ولما جرى الخطاب للنساء جاءت بلفظ والمطلقات كما قوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)[5]

وهذه الآيات واضحة الدلالة أن الزوج هو الذي يطلق وهو الذي يملك حل عقد النكاح بإرادة منفردة منه دون شرط موافقة الزوجة ،ولايجد نصا واحدا يشير إلى أن المرأة تطلق نفسها بإرادة منفردة منها هو الرجل .

**ثانيا : نصوص السنة**

١_ حديث امراة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي[6].

٢_ حديث إبي عمرو بن حفص بن المغيرة الذي خرج مع على بن إبي طالب إلي اليمن فأرسل إلى امرأته فاظمة بين قيس بتطليقه كانت بقيت من طلاقها .[1]

---

[1]– سورة البقرة: الآيه(٢٣٦).

[2]– سورة الطلاق :الآيه (١)

[3]– سورة البقرة : الآيه (٢٣٠)

[4]– سورة التحريم :الآيه (٥)

[5]– سورةالبقرة : الآيه (٢٢٨)

[6]– رواه البخاري في صحيحه : ج٥ ص ٢٠١٤ باب من أجاز الطلاق الثلاث .

٣_ حديث ابن عمر انه طلق امرأته تطليقه وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها.[٢]

ثالثا : أجمع الفقهاء المسلمون على أن للزوج أن يطلق زوجته بإرادة منفردة دون التوقف على إذن أحد أو رضاه.[٣]

من خلا ما سبق يتبين لنا أن صاحب الحق الأصيل في الفرقة هو الزوج وقد أعطى التشريع هذا الحق للزوج أصالة وذلك لأسباب عديدة ترتبط بالقوامة والإنفاق والتركيب النفسي والجسمي ، وترتبط كذلك بقدرة الزوج على التأمل والتفكير مليا بالفرقة ، قدرة ناتجة عن تبعة المسؤوليات الملقاة عليه تجاه قراره ، كالمهر والنفقة وما يتبع ذلك من حقوق للصغار من رضاع ومسكن وغير ذلك مما قد يتكلف به ماديا ومعنويا ، وما سيترتب عليه من نفقات جديدة لزواج آخر كل ذلك يدفعه للتروي وإعادة النظر ، ومحاولة تجاوز العثرات في سبيل المحافظة على الأسر وديمومة الزواج ، وهذا بالنسبة للزوج أما الزوجة فلم تعط هذا الحق استقلالا بإرادتها المنفردة وكذلك لم يعطه الولي لكنهم إن رغبوا في فك عر ى الزوحية فإن عليهم طلب من الزوج أو الرجوع إلى القضاء صاحب الولاية العامة .[٤]

---

[١]– مسلم ، الجامع الصحيح : ١٩٧/٤

[٢]– مسلم ، الجامع الصحيح: ١٨١/٤

[٣]– ابن قدامة ،المغني : ج٧ ص ٢٧٧ (طبعة دار الفكر ١٤٠٥) هجرى .

[٤]– وذلك كطلب الزوجة الفرق بسبب إضرار الزوج بها بغيابه عنها أو عدم إنفاق عليها وطلب الولي الفرقة لعدم الكفاءة.

**السلطة الممنوحة للزوج في استخدام حق الطلاق:**

إن الزوج قد أعطي حق إنهاء العلاقة الزوجتة بكلمة يلفظها وقرار يتخذه وحيدا منفردا ، إلا أن المشرع قد وضع له ضوابط وقواعد لاستخدام هذا الحق ، وفي حال تجاوز تلك الضوابط اعتبر واقعا في الإثم ، في حين جعل البعض طلاقه عير المتفق مع أحكام الشرع لغوا لا أثر له [1]، ومن هذه الضوابط :

الضابط الأول : الحكم التكليفى للطلاق جعل الشارع الأصل فيه الكراهة إذا تجرد عن الأسباب الداعية له ، وقد نظر الفقهاء إلى الحكم التكليفي للطلاق باعتباره متغيرا تبعا لتغير الوصف المتقرن به والسبب الداعى له ، بحيث تشكل تلك الأحكام وتوضح وتحدد السلطة الشرعية الممنوعة للزوج فى الطلاق ، وقد كان النظر وقد كان النظر الفقهي مرتبطا إلى حد ما بالمقصد الشرعي من عقد النكاح ، ومدى تأثره بوجوب الأسباب المختلفة ، التي قد تعود بأصل تشريع النكاح إلى غير الهدف المرجو منه فى تلك الحالات .

ونستطيع أن نتبين ذلك من خلال الاطلاع على كيفية تفصيل الفقهاء للحكم التكليفى لتطليق الزوج فقد ذكر الشافعيه [2] مثلا أن الطلاق يقع على اربعة اوجه واجب ومستحب ومحرم ومكروه فأما الواجب فهو في حالتين إحداهما إذاوقع الشقاق ورأى الحكمان الطلاق ، والثانية إذا آلى من الزوجة ولم يفىء إليها ، وأما المستحب فهو في حالتين الأولى إذا كان يقصر في حقها في العشرة أو في غيرها فالمستحب أن يطلقها ، ولأنه إذا لم يطلقها في هذه الحال لم يؤمن أن يفضي إلى الشقاق أو إلى الفساد ، والثانية ألا تكون المرأة عفيفة فالمستحب أن يطلقها ، ولأنه لايأمن أن تفسد عليه وتلحق به نسبا ليس منه ، والمحرم من

---

[1]– جمهور الفقهاء من الحنيفة والما لكية والشافعية والحنابلة يرون وقوع الطلاق البدعي في حين يرى الظاهرية عدم وقوعه ،انظر في ذلك ، الموصلي، الاختيار : ج٣ ص ١٢٢ ،القاضي عبد الوهاب ،التلقين : ص ٩٤ ، الحصني ،كفاية الأخيار: ص ٥٢١ ، البهوتي، الروض المربع :ص٥٦٢ ،ابن حزم ، المحلى :ج٩ ص ٣٥٦ و ٣٥٧ .

[2]– الشيرازي ،المهذ ب : ج٢ ص ٧٨ .

الطلاق فهو طلاق البدعة وهو اثنان أحدهما طلاق المدخول بها في حال الحيض والثاني طلاق من يجوز أن تحبل في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل ، واما المكروه فهو طلاق سنة ولا بدعة فيه .

أما الحنفية فقد جعلوا من الخطر أصلا للطلاق لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينيه والدنيوية[1].

**ومن تلك الأحكام عند الحنابلة[2].**

١_ الإباحة للحاجة إليه كسوء خلق المرأة والتضرر منها .

٢_ الكراهة وذلك عند عدم الحاجة ،إليه لاشتمال الطلاق على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المنذوب إليها .

٣_ الندب والاستحباب وذلك إذا تضررت المرأة باستدامة النكاح حال الشقاق .

٤_ الوجوب وذلك على الموالي إذا أبى الفيئة .

٥_ الحرمة وذلك حال كونه بدعيا .

الضابط الثاني : المطلق لابد أن يتحرى جلمة أشياء ليكون طلاقه سنيا لا بدعيا ، أي لكي يخرج من دائر الإثم ويحقق الهدف المرجو من الطلاق ولو صورة ، وير تبط الطلاق السني بأمرين بالوقت والعدد قال القاضي عبد الوهاب المالكي :( فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه ، والسنة والبدعة يرجعان إلى أمرين إلى الوقت والعدد، ولطلاق السنة ستة شروط أحدهما أن تكون المطلقة ممن تحيض مثلها والثاني أن تكون طاهرا عير حائض ولا نفساء ، الثالث أن تكون في طهر لم تمس فيه ، والرابع أن يكون الطهر تاليا لحيض لم تطلق فيه ، والخامس أن تطلق واحدة ، والسادس أن

[1]– المر غيناني ، الهداية :ج١ ص ٢٢٧ ،الكا ساني ، البدائع :ج٣ ص ٩٣_٩٥ ، الموصلي : الاختيار : ج٣ ص ١٢١ .

[2]– البهوتي ، الروض المربع : ص ٥٥٩ .

تترك ولا يتبعها _ الزوج _طلاقا ، ومتى انحرم بعض هذه الأوصاف خرج الطلاق عن السنة )[1].

فالحنيفة يعتبرون الطلاق البدعي هو الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أوالثلاث في طهر واحد من حيث العدد ومن حيث الوقت الطلاق في الحيض في المدخول بها أو في طهر جامعها فيه وقد بين الكاساني من خلال بيان طلاق السنة الأصل في حكم الطلاق وأنه الحظر وربط ذلك بمقاصد النكاح بكلام مفيد وحشية التطويل لذكرته .[2]

ولم يعتبر الشافعية الطلاق الثلاث من طلاق البدعة وإن كان خلاف الأولى[3]. بينما عدوا طلاق زوج المرأتين لإحداهن إذا قسم للأخرى قبل المبيت عند المطلقة بدعيا[4] إضافة للطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه[5]، والبدعة عند الحنابلة في الطلاق أن يطلق ثلاثا بكلمة واحدة أوبكلمات والطلاق في الحيض بعد الدخول والطلاق فى طهر جامع فيه.[6]

---

[1]– عبد الوهاب ، التلقين : ص ٩٤ .

[2]– الكاساني ، البدائع : ج٣ ص ٩٣_٩٥ ، المر غينا ني ، الهداية : ج١ ص ٢٢٧

[3]– الغزالي ، الوسيط : ج٥ ص ٣٦٣

[4]– الأنصاري ، فتح الوهاب : ج٢ ص ١٣٩ .

[5]– الشربيني ، مغني المحتاج : ج٣ ص ٣٠٧ ومابعدها .

[6]– البهوتي ، الروض المربع : ص ٥٦١ .

## المبحث الثاني

## مشروعية التفريق القضائي

الحديث عن مشروعية التفريق القضائي ، حديث عن مشروعية الفرقة بين الزوجين استنادا إلى سبب من الأسباب الموجبة للتفريق، أوالمجيزة له، وهذاالاستناد يجعل التشابة قائما بين مشروعية التفريق القضائي ومشروعية الطلاق في نوع واحد منه ، وهو الطلاق حال وجود سبب يبرره ولذا فاذا أردنا أن نربط بين مشروعية التفريق ومشروعية الطلاق فلاتحاد السبب في النوع المذكور ، إذ لايتصور أن يكون التفريق القضائي خاليا عن السبب ، سواء أكان سببا معنويا أو ماديا يخص الزوج أو الزوجة أوالولي أوالحالة الشرعية العامة المرتبطة بالنظام العام المقررة في التشريع ، إلاأن المشروعية في التفريق القضائي أوسع منها مجالا في حالة الطلاق الإرادي المنفرد من الزوج وذلك لتعلقها بعدة نواح :

١_ المشروعية من حيث إن التفريق هو حل لعقد النكاح أو إنهام للرابطة الزوجية وهو في هذا شبيه بالطلاق ومرتبط بمشروعية الطلاق .

٢_ المشروعية من حيث دور القضاء وصلته بإنهاء عقد النكاح ومدى صلاحية القضاء للتدخل بين الزوجين في عقد شخصي بينهما .

٣_ المشروعية في بيان الأسباب التى تجيز التدخل القضائي وطريقة تحديد تلك الأسباب .

٤_ المشروعية من حيث الجهة المثيرة للخصومة لدى القضاء وهو الجهة الطالبة للتفريق فمن هو صاحب الحق في طلب التفريق ومن الذي يشرع له إثارة الخصومة في هكذا أمر .

ولذا فإن الحكم التكليفي للتفريق القضائي يمكن تقسيم النظر فيه إلى قسمين بحسب الجهة مصدرة الحكم بالتفريق والجهة طالبة التفريق:

**القسم ألاول : الجهة المصدرة لحكم الفرقة وهي القضاء .**

إن القاضي عندما تم تنصبيه للنظر في خصومات الناس ، اعتبر هذا تكليفا له بمهمة إقامة العدل وإزالة الظلم ، وإعطاء الحقوق لأصحابها ، فمتى ما ترافع عنده خصمان وجب عليه أن ينظر في خصومتهما [١]، ويحقق في ادعاءاتهما وفق الأصول المرعية عند الفقهاء وأهل العلم ،لأن نصب القضاء أمر واجب ،لاستناده إلى القيام بواجب شرعي ، وهو وسيلة مهمة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. [٢]

**القسم الأخر : الجهة طالبة التفريق**

وهذه متصورة في الزوج ،أو الزوحة ،أوالولي أو طرف رابع وهو المدعي العام ، فما هو الحكم التكليفي لطلب الزوج ؟ ولطلب الزوجة ؟ولطلب الولي ؟ولطلب المدعي العام؟

موقف الشريعة الإسلامية من التفريق القضائي.

**موقف الشريعة لإسلامية من التفريق القضائي وأراء الفقهاء كله**

اتفق أئمة المذاهب الأربعة على التفريق بعيبين، وهما الجب، والعنة، واختلفوا في عيوب أخرى على آراء أربعة:

**الأول: رأي أبي حنيفة، وأبي يوسف:** [٣]

لا فسخ إلا بالعيوب الثلاثة التناسيلة، وهي:(الجب، والعنة، والخصاء)، إن كانت في الرجل؛ لأنها عيوب غير قابلة للزوال (عيوب مستحكمة)، فالضرر فيها دائم، ولا يتحقق معها المقصود الأصلي من الزواج وهوالتوالد والتناسل والإعفاف عن المعاصي، فكان لابد من التفريق.

---

[١]– الشربيني ، مغني المحتاج :ج٤ ص ٣٧٣ .

[٢]– زيدان ، نظام القضاء ص ١٤_١٥ .

[٣]محمد جواد مغنية ، أصول الإثبات في الفقه الجعفري ، ص٢٣ ، نقلاً عن : كتاب المحامي جمعة سعدون الربيعي ، المرشد إلى إقامة الدعوى الشرعية وتطبيقاتها العملية ، الطبعة الثانية ، بغداد ، ٢٠٠٦ ، ص٥.

أما العيوب الأخرى من جنون أوجذام أوبرص أورتق أوقرن، فلا فسخ للزواج بسببها إن كان بالزوجة، ولا إن كانت بالزوج، ولا خيار للآخر بها.وهذا هوالصحيح عند الحنفية.

وقال محمد: للزوجة الخيار، أوالفسخ إن كانت هذه العيوب بالزوج، ولا خيار للزوج إن كانت بالزوجة، وبه يتفق الحنفية على أنه لا خيار للزوج في فسخ الزواج بسبب عيوب الزوجة مطلقا، واختلفوا في الخيار بعيوب الزوج.

**والعيوب عند الشافعية سبعة، وهي:**

الجب، والعنة، والجنون، والجذام، والبرص، والرتَق، والقَرَن، ويمكن أن يكون في كل من الزوجين خمسة، الأولان في الرجل والأخيران في المرأة، والثلاثة الوسطى مشتركة بينهما، ولا فسخ بالبخر، والصنان، والاستحاضة، والقروح السيالة، والعمى، والزمانة، والبله، والخصاء، والإفضاء، ولا بكونه يتغوط عند الجماع؛ لأن هذه الأمور لا تفوت مقصود النكاح. [1]

والعيوب عند المالكية ثلاثة عشر عيباً:

أربعة مشتركة بين الرجل والمرأة: الجنون، والجذام، والبرص، والعَذيْطَة(خروج الغائط أوالبول عند الجماع)ويقال للمرأة عِذيوطة، وللرجل عِذْيوط.

وأربعة تختص بالرجل، وهي: الخصاء، والجَبّ، والعُنَّة، والاعتراض (عدم القدرة على الاتصال الجنسي لمرض أونحوه).

وخمسة تختص بالمرأة، وهي: الرتق، والقرن، والبخر (نتن الفرج)، والعَفَل (غدة تمنع ولوج الذكر أورغوة تمنع لذة الوطء)، والإفضاء (اختلاط القُبُل أي مسلك الذكر بمجرى البول أوالغائط).

وليس من العيوب: القرع، ولا السواد، ولا إن وجدها مفتضة من الزنا على المشهور، وليس منها العمى، والعور، والعرج، والزمانة، ولا نحوها من العاهات، إلا إن اشترط السلامة منها. [2]

---

(١) المحامي جمعة سعدون الربيعي ، المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية ، المصدر السابق ، ص٥ .

(٢) المادة ٤٣ من قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ب– تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق أربعة أشهر وعشرة أيام .

**الثالث: رأي أحمد:**

يفسخ النكاح بالعيوب التناسلية (أوالجنسية)، أوالعيوب المنفرة، أوالعيوب المستعصية كالسل، والسيلان، أوالزهري، ونحوها، مما يعرف عن طريق أهل الخبرة.

والعيوب عندهم ثمانية:

ثلاثة يشترك فيها الزوجان، وهي: الجنون، والجذام، والبرص.

واثنان يختص بهما الرجل، وهما:الجب، والعنة.

وثلاثة تختص بالمرأة، وهي: الفتق (اختلاط مجرى البول والمني)، والقرن، والعفل.

والقاضي أبويعلى جعل القرن، والعفل شيئاً واحداً فتكون العيوب سبعة.

قال أبوالخطاب:ويتخرج على ذلك من به الباسور، والناسور، والقروح السيالة في الفرج؛ لأنها تثير نفرة، وتتعدى نجاستها. [١]

ورجح الحنابلة أنه يثبت الخيار للرجل بقروح سيالة في فرج المرأة، وبباسور، وناسور، ونحوهما.

وليس من العيوب المجوزة للفسخ: القرع، والعمى، والعرج، وقطع اليدين، والرجلين؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه.

**الرابع: رأي الزهري، وشريح، وأبي ثور، واختاره ابن القيم** [٢]

يجوز طلب التفريق من كل عيب منفر بأحد الزوجين، سواء أكان مستحكماً، أم لم يكن كالعقم، والخرس، والعرج، والطرش، وقطع اليدين، أوالرجلين، أوإحداهما؛ لأن العقد قد تم على أساس السلامة من العيوب، فإذا انتفت السلامة فقد ثبت الخيار، ولما روى أبوعبيد، عن سليمان بن

---

(١) زكريا الأنصاري ، فتح الوهاب ، الجزء السادس ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب العلمية ، لبنان – بيروت، ١٩٩٧ ، ص١٢٤ .

(٢) المحامي جمعة سعدون الربيعي ، المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية ، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية ، بغداد ، ٢٠٠٦ ، ص٦٤٨ .

يسار: "أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: أعلمتها؟، قال: لا، قال: أعلمها، ثم خيرها [١]

والذي أميل له: رأي الحنابلة؛ لعدم تحديد العيوب، ولأنهم قصروا جواز الفسخ على العيب الذي لا تتم معه مقاصد الزواج على وجه الكمال، وهذا هوالمتفق مع مقتضى عقد الزواج، وقواعد الشريعة السامية. [٢]

قيود الفرقة بالعيب:

اتفق الفقهاء على أن الفرقة بالعيب تحتاج إلى حكم القاضي وادعاء صاحب المصلحة؛ لأن التفريق بالعيب أمر مجتهد فيه ومختلف فيه بين الفقهاء، فيحتاج إلى قضاء القاضي لرفع الخلاف، ولأن الزوجينيختلفان في ادعاء وجود العيب وعدم وجوده، وفي أنه يجوز التفريق به أولا يجوز، وقضاء الحاكم يقطع دابر الخلاف، والقول قول منكر العلم بالعيب، مع يمينه، في عدم علمه بالعيب؛ لأنه الأصل.

وإذا تبين أن الزوج مجبوب، فرق القاضي بين الزوجين في الحال ولم يؤجله؛ لعدم الفائدة في التأجيل. [٣]

أما العنِّين، والخصي، فيؤجله الحاكم سنة من تاريخ الخصومة، أي الدعوى والترافع، عند الحنفية والحنابلة، لاحتمال أن تثبت قدرته على الجماع في أثناء السنة على مرور [٤] الفصول،

---

(١) د. رمضان علي السيد الشرنباصي والدكتور جابر عبد الهادي سالم الشافعي ، المصدر السابق ، ص١٢٥.

(٢) الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي، ت – ١٢٧٠هـ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، والسبع المثاني، ط . ١٣٩٨هـ . ١٩٧٨م، دار الفكر . بيروت

(٣) الجصاص: الأمام أبو بكر أحمد الرازي الجصاص، ت . ٣٧٠هـ ، أحكام ١ القرآن، راجعه رشيد رضا: الإمام محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ط . الهيئة المصرية العامة للكتب . ٥. السايس: الشيخ محمد على السايس، تفسير آيات الأحكام، ط . محمد على صبيح.

(٤) صدقي محمد جميل، ط .١٤٢١ هـ – ٢٠٠١م، دار الفكر . بيروت

والتأجيل سنة مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وتبدأ السنة عند الشافعية، والمالكية من وقت القضاء بالتأجيل، عملاً بقضاء عمر الذي رواه الشافعي، والبيهقي. [1]

فإذا ادعى الزوج أثناء السنة حدوث الجماع:

ففي رأي الحنفية، والحنابلة:

إن كانت المرأة ثيباً، فالقول قول الزوج بيمينه؛ لأن الظاهر يشهد له؛ لأن الأصل السلامة من العيوب، والقول لمن يشهد له الظاهر بيمينه، فإن حلف رفضت دعوى الزوجة، وإن امتنع عن الحلف، خيرها القاضي بين البقاء معه على هذه الحال وبين الفرقة، فإن اختارت الفرقة فرق بينهما، وإن كانت بكراً عذراء نظر إليها النساء، ويقبل قول امرأة واحدة، والأولى عند الحنفية إراءتها لامرأتين، فإذا قالتا: هي بكر، بقي التأجيل لنهاية السنة لظهور كذبه، وإن قالتا: هي ثيب، حلّف الزوج، فإن حلف لاحق لها، وإن نكل بقي التأجيل سنة، فإن شهدت النساء، وإلا فالقول قولها.

وقال المالكية:

إن ادعى الوطء في مدة السنة، صدق الزوج بيمينه، وإن نكل عن اليمين حَلَفت الزوجة: إنه لم يطأ، وفرق بينهما قبل تمام السنة إن شاءت.

أما إن كان العيب غير الجب أوالعنة أوالخصاء، ففي رأي المالكية، إن كان العي لا يرجى زواله بالعلاج، فرق القاضي بين الزوجين في الحال، وإن كان يرجى زواله بالعلاج، أجل القاضي التفريق لمدة سنة إن كان العيب من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة كالجنون، والجذام، والبرص.

---

(١) الرازي: الإمام محمد فخر الدين الرازي، ت – ٦٠٤ هـ، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، ط .١٤٠١ هـ. ١٩٨١ م، دار الفكر . ١ بيروت

وإن كان من العيوب الخاصة بالمرأة فيؤجل التفريق بالاجتهاد حسبما تقتضي حالة العلاج من العيب، وإن ادعت المرأة أنها برئت من عيبها صدقت بيمينها. [1]

(١) رشيد رضا: الإمام محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ط . الهيئة المصرية العامة للكتب . ٥. السايس: الشيخ محمد على السايس، تفسير آيات الأحكام، ط . محمد على صبيح.

## الخاتمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد:

فإنه في ختام إعداد وعرض هذه الدراسة أسأل الله العلي القدير لأن أكون قد وقفت فيما اردت أصل إليه من خلال هذا العمل، وكل صنع البشرية يعتريه النقص والخلل، فالكمال لله وحده والعصمة لمن عصم من خلقه بأمره وتقديره فما اصبت فيه فكله فضل من الله وهداية،وما أخطأت فيه فقصور في نفسي،وهو تشديد ومقاربة أملا في الخير والفلاح.

لقد توصلت الباحثت من خلال دراستها الموضوع( الحالات التي يفرق القاضي بين الزوجين) على النتائج والتوصيات التالي:-

**أولا: النتائج:**

١. يظهر من خلال إمعان النظر في مطالب البحث مجموعة من النتائج تعد هي الثمرة الحقيقية لهذا البحث .
٢. المعروف إن فقهاء المسلمين قد حصروا إنهاء العلاقة الزوجية بيد الزوج أصلاَ والاستثناء لا يرد إلا في حالات خاصة ومضيقة تتضرر فيها الزوجة مع ضبطه بنظر الحاكم.
٣. إن أغلب صور التفريق القضائي لو تمت بتمام موجبها كانت الفرقة بين الزوجين بائنة لتحقيق الغرض من التفرقة إذ لو كانت رجعية فبرجوع الزوج ينتفي الغرض من التفرقة، أما في الطلاق البائن لا يحق له الرجوع إلاّ برضا طرفي العقد.

٤. إن أغلب الفقهاء عندما ذهبوا إلى جواز التفريق القضائي كان مستندهم في معظم الأحيان القاعدة الفقهية التي أسسها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله : ((لا ضرر ولا ضرار))

٥. المسموح وبحدود الروايات الصادرة عن المعصوم إن التفريق لا يتم إلاّ بعدم الإنفاق أو العيب المفضي لقيام الزوج بالمهام الجنسية فلذلك اشتهر عندهم حصر التفريق بهاذين الموردين وندر عند المتقدمين غيرها من الصور ،أما بعض المتأخرين والمعاصرين ممن استطاع تأويل النصوص أن يوسع دائرة التفريق بما يشمل الشقاق والغيبة والسجن مثلاَ.

**الثاني:التوصيات**

التوصيات : بعد الوقوف على عدد من الحقائق؛ فإن الحاجة تدعو إلى تسجيل بعض التوصيات وهي كما يلي:

١. إن قانون الأحوال الشخصية، هو البقية الباقية المستمدة من أحكام الشريعة؛ لذا فإن من واجب طلبة العلم الشرعي، وخاصة المنتسبين إلى قسم القضاء، النهوض بهذا القانون، وإجراء أبحاث ودراسات على أقسامه المختلفة؛ لإخراجها في ثوب جديد، يتناسب وتغير الزمان والأحوال، مراعين في ذلك عدم الخروج عن الأصول الشرعية

٢. يبدو واضحاً في هذا الزمان، حجم الغزو الفكري والثقافي، الذي يحاول الغرب من خلاله التأثير على مفاهيم المرأة المسلمة؛ لتغيير عاداتها ومعتقداتها؛ لذا فإن من واجب العلماء التصدي لهذه الهجمة المجنونة، من خلال إصدار الأبحاث والنشرات والمقالات التي ترد هذه الهجمة وتظهر مكانة المرأة في الإسلام

٣. إن لجهاز التعليم دوراً كبيراً في بناء المجتمع؛ لذا فإن من واجب المسؤولين عن هذا الجهاز، العمل على تطوير مناهجه، بما يتناسب مع حاجة المجتمع المسلم، وأقترح لذلك ما يلي

أ . تخصيص مادة تربوية إسلامية، تهتم بالعلاقات الأسرية عموماً، وتدرس لطلبة وطالبات الصف التاسع

ب . تقرير مادة تربوية، تدرس لطلبة وطالبات الصف العاشر، يرسخ من خلالها مبدأ التعاون والتكافل بين الزوجين، ثم بيان ما على كل منهما نحو الآخر من منظور إسلامي

٤. من واجب المسؤولين في المؤسسات التعليمية والاجتماعية والأهلية؛ كالجامعات ومجالس الطلبة، وجمعية الشابات المسلمات، العمل على تفعيل الدور التعاوني بينها وبين المحاكم الشرعية لما فيه صالح الأسرة والمجتمع.

# فهرس الايات

| الآية | السورة | الآية | الصفحة |
|---|---|---|---|
| (فقضاهن سبع السماوات فى يومين ) | فصلت | ١٢ | |
| (فاقض مآنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ) | طه | ٧٢ | |
| (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا | النساء | ١٤٥ | |
| (قاتلو الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر | التوبة | ٢٩ | |
| ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب) | الحج | ٤٦ | |
| ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس | الحج | ٤٦ | |
| ( وإن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب | الأعراف | ١٧٩ | |
| ياأيها الذين آمنوا لا تتخذو اليهود والنصاري | المائدة | ٥١ | |
| ( إن الله يامركم ان تؤدو الأمانات إلى اهلها | النساء | ٥٨ | |
| ( الرجال قوامون على النساءبما فضل الله | النساء | ٣٤ | |
| (لاتجعل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه) | طه | ١١٤ | |
| نحن أولوا قوة أولوا بأس شديد والأمر إليك | النمل | ٣٢ | |
| ( رب إني ظلمت نفسي وأسلمت نفسي | النمل | ٤٤ | |
| فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى | البقرة | ٢٨٢ | |
| وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) | الحجرات | ٩ | |
| (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا | النساء | ١٢٨ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ( لاخيرفي كثير من نجواهم | النساء | ٢١٤ | |
| (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف | النساء | ١٣٠ | |
| ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) | النساء | ١٣٠ | |
| ( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن | الطلاق | ١ | |
| ﴿ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ | المائدة ٤٩ | | |
| (فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره | البقرة | ٢٣٠ | |
| عسى ربه إن طلقكن ان يبدله أزواجا خير | التحريم | ٥ | |
| (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) | البقرة | ٢٢٨ | |

# فهرس الأحاديث


| الحديث | الصفحة |
| --- | --- |
| الا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله | |
| :" لن يفلح قوم ولو امرهم أمراة" | |
| لا ضر ولاضرار | |
| ما رأيت من ناقصات عقل ودين | |
| إن رفاعة طلقني فبت طلاقي | |

**فهرس المصادر والمراجع**

أولا: القرآن الكريم

ثانياً: السنة النبوية

**ثالثاً: الكتب**


٢-ابن الهمام، فتح القدير، ج٧، ص٢١٩.

٣-ابن صويان، منار السبيل، ج٢، ص٤٠٧.

٤-ابن قدامة ،المغني : ج٧ ص ٢٧٧ (طبعة دار الفكر ١٤٠٥) هجرى .

٥-ابن نجيم، البحر الرائق ص ٢٥٢ ج ٤ ،ابن الهمام ، فتح القدير : ص ٤٦٣ ج( ٣) .

٦-ابن نجيم، البحر الرائق، ج٧، ص١٧.

٧-ابن نجيم، البحر الرائق، ج٧، ص٢٧.

٨-الأحدب، عبد الحميد، التحكيم بالصلح في الشرع الإسلامي منشور في مجلة المؤتمر الإسلامي الثاني للشريعة والقانون، لبنان، ص١٥٢ و١٥٦ وما بعدها.

٩-أخرجه البخاري برفم (٤٤٢٥) الترمدي في كتاب القضاء برقم(٢٢٦٢)النسائى في كتاب القضاء باب النهي عن استعمال النساء فى الحكم برقم ، (٥٣٩٠) ، ص (٨٣٠).

١٠- الاشباه والنظائر ،للسبكي (١٧/٢)

١١- الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي، ت – ١٢٧٠هـ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، والسبع المثاني، ط . ١٣٩٨هـ . ١٩٧٨م، دار الفكر . بيروت

١٢- الأنصاري ، فتح الوهاب : ج٢ ص ١٣٩ .

١٣- البخارى باب المسا فا ت (٢٠/١)، البيهقي (٢٦٤/٥)

١٤- بداية المجتهد ،(٤/ ١٧٧٢).

١٥- بداية المجتهد،( ١٧٧٣/٤) ، الرضة (٢/٢٥٤_٣٠). المغني ،لابن قدامة!١٢/٤_١٨)، الكافي ،لابنقدامة، (٨٦/٦)، الميزان الكبرى ،(٢،/٢٨_٢٦١).

١٦- البهوتي ، الروض المربع : ص ٥٦١ .

١٧- تفسير القرآن العظيم ،(٦٤١/١_٦٤٢) سبل السلام(١٦٩/٤، رقم الحديث (٥٣٩٠) بحوث فقهية، ص (١٢٨ )تفسير البغوي (٥٣٤/٤)

١٨- تفسير آيات الأحكام للجصاص، (٦٢١/١ – ٢٢٩)، وسائل الإثبات د.محمد الزحيلي (١٩٧/١) والقواعد الفقهية د.أحمد علي الندوي

١٩- الجصاص: الأمام أبو بكر أحمد الرازي الجصاص، ت . ٣٧٠هـ ، أحكام ١ القرآن، راجعه رشيد رضا: الإمام محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ط . الهيئة المصرية العامة للكتب . ٥. السايس: الشيخ محمد على السايس، تفسير آيات الأحكام، ط . محمد على صبيح.

٢٠- الحصني، كفاية الخيار : ص ٣١٦ ؛ ابن النجار ،، منتهى الارادات : ج٢ ص ٩٥ .

٢١- الخطا ب ، مواهب الجليل : ص ١٨ ج (٤) .

٢٢- الخطاب: مواهب الجليل: ج٦، ص١١٢.

٢٣- الد ميا طي ، اعانة الطا لبين : ج ٣ ص ٣٠٣ .

٢٤- الرازي: الإمام محمد فخر الدين الرازي، ت – ٦٠٤ هـ، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، ط .١٤٠١ هـ. ١٩٨١ م، دار الفكر . ١ بيروت

٢٥- رشيد رضا: الإمام محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ط . الهيئة المصرية العامة للكتب . الشيخ محمد على السايس، تفسير آيات الأحكام، ط . محمد على صبيح.

٢٦- الروض المربع ،(٣٨٥/٣).

٢٧- الزرقاني ، شرح الزرقاني على المو طأ : ص ٢١٦ ج (٣) .

٢٨- زكريا الأنصاري ، فتح الوهاب ، الجزء السادس ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب العلمية ، لبنان – بيروت، ١٩٩٧ ، ص١٢٤ .
٢٩- زيدان ، نظام القضاء ص ١٤_١٥ .
٣٠- شرائع الإسلام (٥٦/٤)، البحر الزخار (١١٩/٦)، شرح المقنع (٤٣١/٦).
٣١- الشربيني ، مغني المحتاج : ج٣ ص ٣٠٧ ومابعدها .
٣٢- الشربيني ، مغني المحتاج : ص ٢٧٩ ج (٣)
٣٣- الشربيني، مغني المحتاج، ج٤، ص٢٧٩، البهوتي، كشاف القناع: ج٦، ص٣٠٩.
٣٤- شرح رد المحتار (٣٨/٨)، بداية المجتهد (١٧٦٨/٤)، المعني (١٤/١٤)، القواعد الفقهية لعبد الرحمن ابن عبد المجيد، ص(٣٢٩).
٣٥- شرح رد المحتار، (٣٨/٨)، الحاوي الكبير، مجموع النووي، المغني (١٦/١٤) الكافي، الشرح الكبير، حاشية الدسوقي.
٣٦- الشيرازي ،المهذ ب : ج٢ ص ٧٨ .
٣٧- صدقي محمد جميل، ط .١٤٢١ هـ – ٢٠٠١م، دار الفكر . بيروت
٣٨- الطحاوي، مختصر اختلاف الفقهاء، ج٤، ص١٠٣.
٣٩- علي الخفيف ،فرق النكاح : ص (١)
٤٠- عمل المرأة القانونية د.أبو مدين الطيب البشير، ص(٨٩ – ٩٩)، رسالة الدكتوراه بجامعة إفريقيا العالمية كلية الشريعة والقانون عام (٢٠٠٢م – ١٤٢٣هـ)
٤١- الغزالي ، الوسيط : ج٥ ص ٣٦٣
٤٢- فتح القدير،(٢٧٠/٩)
٤٣- القاضي عبد الوهاب ، التلقين : ص ٩٧ .
٤٤- القاضي عبد الوهاب ، التلقين : ص ٩٧ .

٤٥- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٤٧/١). وقد فصل القول الشيخ عبد الرحمن في كتابه "القواعد الفقهية" المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين، ص(٣٢٩)، ومفتاح دار السعادة، لابن قيم الجوزية، ص(٣٥٠).

٤٦- الكاساني ، البدائع : ج٣ ص ٩٣_٩٥ ، المر غينا ني ، الهداية : ج١ ص ٢٢٧

٤٧- الكاساني، البدائع: ج٦، ص٥٣، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص٢٢٢.

٤٨- الكاساني، بدائع الصنائع: ج٧، ص٣، ابن الهمام، فتح القدير: ج٧، ص٣١٧.

٤٩- لأبي جعفر (٥٦٧/٤) ، رسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة ، تفصيل ذلك في الشرائع الإسلام، لأبي جعفر (٥٦٧/٤) ، ورسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة، لمحمد ابن الحسن (١١٧/١٧)، مواهب الجليل ،(٨٧/٦)،الأحكام السلطانيه للماوردي ص (٧٢)

٥٠- المحامي جمعة سعدون الربيعي ، المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية ، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية ، بغداد ، ٢٠٠٦ ، ص٦٤٨ .

٥١- المحلي بالاثار (٦٣١/١٠)،القضاء في عهد عمر (٢٩/١) بحوث فقهية ،ص (٩٨).

٥٢- محمد جواد مغنية ، أصول الإثبات في الفقه الجعفري ، ص٢٣ ، نقلاً عن : كتاب المحامي جمعة سعدون الربيعي ، المرشد إلى إقامة الدعوى الشرعية وتطبيقاتها العملية ، الطبعة الثانية ، بغداد ، ٢٠٠٦ ، ص٥.

٥٣- المر غيناني ، الهداية :ج١ ص ٢٢٧ ،الكا ساني ، البدائع :ج٣ ص ٩٣_٩٥ ،

٥٤- المغني ،لإبن قدامة، (١٣/١٤_٢٥).

٥٥- مغني المحتاج، (٢٧٥/٦).

٥٦- المغني، (٥٦/٩)، المقنع (٦١٣/٣)، وراجع تفصيل ذلك الحاوي الكبير، (١٧١/١٦١ – ١٧٤)، القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين، لأبي عبد الرحمن بن عبد المجيد، ص(٣٢٣)، الأم (٢٧٦/٦) و(٢٨٠).

٥٧- الموصلي، الاختيار : ج٣ ص ١٢٢ ،القاضي عبد الوهاب ،التلقين : ص ٩٤ ، الحصني ،كفاية الأخيار: ص ٥٢١ ، البهوتي، الروض المربع :ص٥٦٢ ،ابن حزم ، المحلى :ج٩ ص ٣٥٦ و ٣٥٧ .

٥٨- نظام القضاء في الإسلام د.إبرهيم عبد الحميد ص (٣١_٣٢)

٥٩- نيل الاوطار (١٦٧/٩)

٦٠- والمدخل الفقهي العام للزرقاء، فقد فصل القول في قضية الضرورة وذكر جميع الواجبات (٩٨٣/٢ – ٩٨٩

٦١- الوجير في شرح القواعد الفقهية، د. عبد الكريم زيدان ،(٨٥)

# فهرس الموضوعات


| الموضوع | الصفحة |
|---|---|
| الاستهلال | ب |
| الاهداء | ج |
| الشكر والتقدير | د |
| المقدمة | 1-2 |
| أسباب اختيار الموضوع | 3 |
| مشكلة البحث | 3 |
| أهمية البحث | 3-4 |
| أهداف البحث | 4 |
| منهج البحث | 4 |
| أسئلة البحث | 4-5 |
| حدود البحث | 5 |
| وسائل أدوات البحث | 5 |
| هيكل البحث | 6-7 |
| **الفصل الأول**<br>**جهة اصدار الحكم.** | **8** |
| المبحث الاول: القاضي، تعريف القاضي. | 9 |
| المبحث الثاني: شروط القاضي قي الإسلام، آداب القاضي، نقص الحكم وأثره. | 9-25 |
| المبحث الثالث: مجال التحكيم في مسائل التفريق وعلاقة التحكيم بالقاضي. | 26-31 |
| **الفصل الثاني**<br>**مفهوم التفريق القضائي.** | 32-33 |
| المبحث الاول: تعريف التفريق لغة وفي إصطلاح الفقهاء. | |

| | |
|---|---|
| المبحث الثاني: أسباب التفريق القضائي. | 33-36 |
| المبحث الثالث: أسباب اللجوء الولي إلى تفريق القضائي. | 37-38 |
| **الفصل الثالث**<br>**التكيف الفقهي القضائي للتفريق ومشروعيته.** | **39-40** |
| المبحث الاول: صاحب الحق في فرقة بين الزوجين. | 41-46 |
| المبحث الثاني: مشروعية التفريق. | 47-48 |
| المبحث الثالث: موقف الشريعة الإسلامية من التقريق القضائي وآراء الفقهاء كله. | 48-53 |
| **الخاتمة** | **54** |
| النتائج | 54-55 |
| التوصيات. | 55-56 |
| **الفهارس** | |
| فهرس الآيات. | 57-58 |
| فهرس الأحاديث. | 59 |
| فهرس والمصادر والمراجع. | 60-64 |
| فهرس الموضوعات. | 65-66 |
| | |